

法律行為解釋、契約解釋與法律解釋^{*} ——以民法第98條之立法溯源與實務運用為中心

吳從周^{**}

摘要

本文從德國法繼受的立法溯源及反思臺灣法在實務上之運用，研究我民法第98條涉及的兩個核心問題：法律行為解釋與契約解釋有何不同？法律行為解釋與法律解釋在解釋標準上如何運用？

第一、關於法律行為解釋與契約解釋，我學界在對於第98條「探求當事人真意」之理解上，應該避開意思說與表示說之爭論，不必再去思考探求「當事人主觀真意」之誤解，而是應由法官透過法律行為解釋的主要階段，即規範性解釋（闡釋性解釋）之方法，確定當事人「真正被表示的意思」。

第二、在最主要的闡釋性解釋上，涉及法律行為解釋與法律解釋在解釋標準上之運用，我最高法院曾經明白宣示過「六準則說」。本文透過對臺灣法律判決實務中對法律行為解釋標準之歸納與重整，期待能藉由類型化之觀察重整，貫徹「六準則說」，以提高臺灣判決實務涉及法律行為或契約之解釋標準與解釋結果之可預測性。

* 投稿日：2017年9月11日；接受刊登日：2018年1月19日。〔責任校對：林庭伊〕。

本文初稿曾先後於2014年6月18日在中央研究院法律學研究所舉辦之「兩岸四地法律發展」學術研討會，及2014年9月26日國立臺灣大學舉辦之「法院的契約觀：華人社會的實踐」學術研討會上朗讀初稿，但未曾完稿發表，嗣經增刪修改後完成本文。

** 國立臺灣大學法律學院副教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/60400181.pdf>。



關鍵詞：法律行為解釋、契約解釋、法律解釋、經驗性解釋、闡釋性解釋、補充性解釋、真意、文字、意思說、表示說。

目次

壹、問題之提出	四、法律行為解釋之三階段： 經驗性解釋、闡釋性解釋 與補充性解釋
一、最高法院88年度台上字第 1671號民事判決（「巴里 島社區案」）之啟發	參、法律行為解釋與法律解釋
二、待討論之問題	一、法律行為解釋與法律解釋 之異同
三、論題之研究現況	二、法律行為解釋之「六準則」
貳、法律行為解釋與契約解釋	三、解釋標準間之位階關係？
一、德國法規定之交錯與釐清 困難	四、觀察臺灣法院的契約解釋 類型
二、立法史上的觀察	肆、結論
三、法律行為解釋之目標	

壹、問題之提出

一、最高法院88年度台上字第1671號民事判決（「巴里島社區案」）之啟發

關於法律行為解釋之方法，可以舉最高法院在涉及法律行為解釋之見解時，常被引用的代表性判決最高法院88年度台上字第1671號民事判決一案（以下簡稱「巴里島社區案」）為例，作為思考的基點。該案之事實可簡化為：原告甲與被告乙公司簽訂土地及房屋預定買賣契約，承購「巴里島社區」B區五棟九樓之房屋及其基地土地（簡稱ABC地）之應有部分，其中土地預定買賣契約書第10條約定：「本契約土地如與鄰地（D地）合併為完整街廓時，甲同意

變更增建為十五、十六層，且有關房屋所持分之土地則依現有建築基地與上開地號土地之面積總和計算分配之」、第12條約定：「如乙違反本契約不能交付時，乙除按照甲已繳付價款退還甲外，並應另付甲前開已繳款金額作為違約金及損害賠償」。嗣乙將原建物上所坐落之ABC地與D地合併，乙卻在該D地上另建十層樓之建築一棟，並對外銷售，且因D地上建物亦可分配ABC地，致甲土地之應有部分比例較原訂契約減少，依土地及房屋預定買賣契約書第12條約定，故乙除應退還甲已繳付之價款外，並應另給付甲同金額之違約金或損害賠償金，乃訴請被告乙給付。乙則抗辯其已於D地與原有建築基地ABC合併後，按其面積總和計算，將甲所應分配之土地應有部分移轉登記與甲，並無違約情事。

兩造之爭點集中在對土地預定買賣契約書第10條之解釋上。甲主張：該條約定係指當鄰地即D地併入本契約土地即原ABC地成為完整街廓時，「巴里島社區」之樓房可變更增建為十五、十六層，斯時該D地應歸屬ABC地上三棟之承購戶共同持有使用，乙就該D地不得再為任何處分，包括建屋出售等語；乙則抗辯稱：D地與契約所訂之ABC地合併成完整街廓時，伊並未放棄或喪失該D地之所有權，自得在D地上增建房屋。

問題在於：本件當事人之真意為何？本契約之目的為何？契約第10條中之「有關房屋」係指ABC地上之房屋，抑或包括D地上之房屋？

為期易於思考，茲先圖示如下：

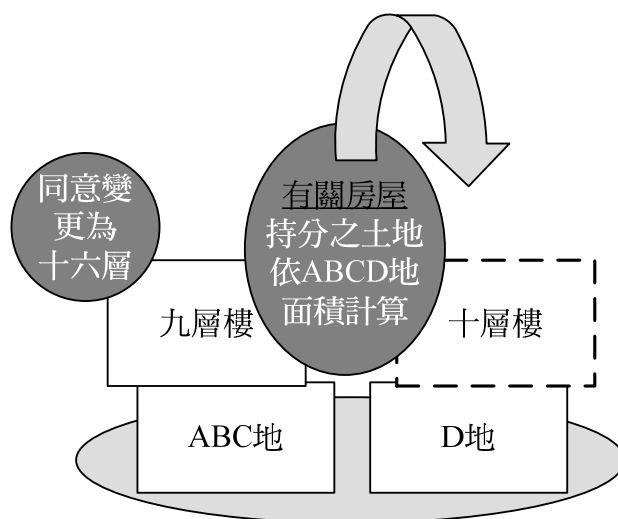


圖1 巴里島社區案圖示

資料來源：作者自製。

對此，最高法院強調：

按解釋意思表示應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。意思表示不明確，使之明確，屬意思表示之解釋；意思表示不完備，使之完備，屬意思表示之補充。前者可減少爭議，後者可使意思表示之無效減至最低程度。意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思。當事人為意思表示時，格於表達力之不足及差異，恆須加以闡釋，至其內心之意思，既未形之於外，尚無從加以揣摩。故在解釋有對話人之意思表示時，應以在對話人得了解之情事為範圍，表意人所為表示行為之言語、文字或舉動，如無特別情事，應以交易上應有之意義而為解釋，如以與交易慣行不同之意思為解釋時，限於對話人知其情事或可得而知，

否則仍不能逸出交易慣行的意義。解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，解釋契約尤須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。關於法律行為之解釋方法，應以當事人所欲達到之目的、習慣、任意法規及誠信原則為標準，合理解釋之，其中應將目的列為最先，習慣次之，任意法規又次之，誠信原則始終介於其間以修正或補足之¹。準此以觀，本件應認定兩造之真意係甲同意當鄰地D地與原ABC地合併時，因乙規劃為完整街廓，可變更增建該三棟樓房為十五、十六層，而使甲獲有增建一、二層房屋得以出售之利益，但乙應提供D地與ABC地合併計算總面積後，分配與各該ABC地上三棟有關房屋之客戶，不得有何減損甲取得基地應有部分之行為，方符契約當事人之目的解釋，並與誠信原則不悖。乃乙於「巴里島社區」樓房變更建築為十五、十六層之同時，竟在D土地上興建十層建築物，致甲分配之房屋基地面積減少，顯已違反前開土地預定買賣契約第10條之約定。至上開條文所稱「有關房屋」之意義，按諸兩造之契約乃上訴人與ABC地上三棟購買戶訂立之定型化附和契約，解釋上，自應作有利於為經濟上弱者之承買人之詮釋，亦即乙與某甲訂立者，應指某甲買受之房屋，與某乙訂立者，則指某乙買受之房屋。因之，於本件情形下，該

¹ 本判決此段有關解釋標準／方法（當事人目的、習慣、任意法規及誠信原則）及其適用之次序（「其中以目的最富事實性，習慣次之，任意法規又次之。依此標準，其決定有不同時，以最富於具體的事實性者為最優先，以當事人所欲達之目的為第一次序。習慣可推定當事人有依從之意思或就其事項無任意法規者，為第二次序。任意法規為第三次序。習慣為當事人所不知者，任意法規為第二次序。誠信原則，就表示內容之決定非與其他標準爭其先後，而係修正或補足應依其他標準所決定之表示之內容。」），遍尋相關民法總則中文書籍後，根據其文字的高度雷同，筆者推測其文字應係參考自史尚寬，民法總論，頁416以下，特別是頁423（1990年）。但因最高法院並未引註說明出處，筆者僅能作此臆測。

條所謂「有關房屋」應係指（甲承購之）B區第五棟第九層房屋甚明。乙執該條後段之約定，抗辯其已依約將原有建築基地與D地合併，並將ABCD地上「有關房屋」，按全部土地面積總和計算，將甲所應得之土地辦理移轉登記，並無違約云云，顯係誤解契約之文義²。

二、待討論之問題

上開判決至少涉及以下兩個主要的問題待討論：

- （一）解釋法律行為之目的（目標）為何？最高法院說：「在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性」究何所指？

臺灣民法第98條規定：「解釋意思表示應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句」，乃有關意思表示之內容不清或缺漏如何解釋之基本規定。但是意思表示究竟應該如何解釋，特別是在當事人的「真意」與所用之「辭句」不一致時，究竟應該以「內在真意」或者「外在辭句」為優先？涉及解釋的目標為何？這背後同時涉及到的關鍵問題是：法律行為解釋與契約解釋有何不同？或者詳細點說：下述德國民法第133條有關法律行為解釋及第157條有關契約解釋之規定，適用上有無不同？

- （二）法律行為解釋之「標準」究竟為何？

從這個判決的涵攝操作過程可以發現，最高法院並沒有清楚地說明，其所使用的解釋方法究竟為何？只看到最高法院先臚列並堆疊了四種所謂解釋的「標準」：分別是契約目的、交易習慣、任意法規與誠信原則，作為「大前提」，然後隨即看不出步驟地得出對事實「應如此認定」，始符合當事人真意與當事人契約之目的解釋

² 本文之粗體字部分，原則上為筆者所自行加上、予以強調，以下同。

之小前提與結論。看不出法律行為之解釋何以以此四者為限？法律行為解釋之「標準」究竟為何？標準之間有無優先順序？解釋法律行為有無一定的步驟？這涉及到的關鍵問題是：法律行為解釋與法律解釋有無不同？法律解釋已經發展出的諸多解釋「標準」及其順序，在法律行為解釋能否完全適用？如何適用？如果標準之間一如法律解釋結果相衝突時，有無何者具有優位性？

三、論題之研究現況

數十年來，我民法學界對於「法律行為之解釋」或「契約之解釋」內涵，主要還是停留在其基礎內涵的介紹與說明³，似乎欠缺一篇兼顧理論與實務見解之專文討論⁴，以至於我民法關鍵的第98條究竟如何適用，理論與實務人云云殊。一直到近年，王文字教授撰寫「契約定性、漏洞填補與任意規定：以一則工程契約終止的判決為例」⁵，喚起吾人重新省思契約漏洞填補的法律上難題，更寓有著從法律行為解釋的基本理論出發研究，整理實務見解之根本性啟示。

相較而言，關於此一問題之德國文獻汗牛充棟，討論已經超過一百年。Erich Danz於其1897年所著「法律行為之解釋」一書中，就說道：「我的這個論題，我們可以說就像法官每天吃飯一樣重要……是一個相當必要的文獻」⁶，這個專論標記了其他相關文獻

3 已具有相當深度的教科書基本說明，可參見王澤鑑，民法總則，增訂新版，頁448-464（2014年）。又相當程度的法律行為解釋，特別是對民法第98條所謂當事人真意之內涵說明及契約漏洞補充問題，參見黃茂榮，法學方法與現代民法，增訂6版，頁409-414（2009年）。

4 對於此一論題，相較而言中國大陸的專論文獻討論反而相對深入，參見朱慶育，意思表示解釋理論（2004年）；朱慶育，民法總論，2版，頁209-227（2016年）。

5 參見王文字，契約定性、漏洞填補與任意規定：以一則工程契約終止的判決為例，臺大法學論叢，38卷2期，頁131-186（2009年）。

6 Erich Danz, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte: Zugleich ein Beitrag zur Rechts- und Thatfrage, 1897, S. 3.

如潮水般大量發表的開端，特別涉及的是法律行為解釋的目標是主觀說或客觀說？一直到1930年Karl Larenz發表了他的教授資格論文「法律行為解釋之方法」(Die Methode der Auslegung der Rechtsgeschäfte)，針對這個問題予以解決，才劃下一個問題討論的暫時性終點。

在1940年11月21日德國的帝國司法部針對德國契約法召開的一次特別學術會議中，當時的一位報告人Werner Vogels針對德國民法第133條及第157條規定的存在實益，曾經這樣一語中的說：「德國民法第133條及第157條……原本正屬整部民法的固有核心(Die §§ 133 und 157 sind gerade eigentlich die Quintessenz des gesamten bürgerlichen Rechts)。吾人可以說：幾乎帝國法院時代四分之三的法院民事判決，都與德國民法第133條、第157條及第242條的論爭有關。這三個條文就足以滿足有權之法官，去作任何他們想作的事！」⁷

在1976年時德國即曾有學者撰文短暫結算說道：「有關意思表示之解釋方法的論文，從1900年以來，至少有超過200位以上之作者直接針對這個論題發表過超過400篇以上的論文。」⁸

可見，法律行為解釋或者契約解釋，一直是一百多年來德國民法解釋學的中心難題，也是永恆的問題。相應而言，民法解釋學令人困擾的難題一直是，其任務究竟是要確定：事實上是法官的意思還是法律行為當事人之意思？亦即：究竟應該私法自治還是法官

⁷ 引自Stefan Vogenauer, in: Schmoeckel (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. I, 2003, §§ 133, 157 Rn. 1。按德國民法第133條是有關法律行為解釋(相當於我民法第98條)，第157條是有關契約解釋(我民法未就此特別規定)，第242條是有關誠信原則之規定(相當於我民法第148條)，Vogels這句話的意思就是：民事法官只要有意思表示解釋及誠信原則這兩個條文，就可以處理四分之三以上的民事事件了！由此亦可見法律行為解釋規定之重要性。

⁸ Dietrich Bickel, Die Methoden der Auslegung Rechtsgeschäftlicher Erklärungen, 1976, S. 9 Fn. 1.

（國家）干預？個人利益還是透過法官個人化之後的共同利益？個人自由還是約束個人⁹？

法律解釋與法律行為的解釋一樣，都涉及兩個主要的難題：其一為解釋的目標何在？探求當事人主觀的意思（意思說）或者探求當事人客觀化之意思表示（表示說）？其二為解釋之標準（*Auslegungskriterien*）¹⁰為何，究竟哪些表徵或狀況可以推論出表意人之意思或表示之客觀意義？

不過，第一個永恆難題的法律解釋目標之爭，雖然重要但畢竟仍屬於抽象的形上層次，且不免具有意識形態的抽象高度，真正的問題解決，仍然不得不回到下位的日常法律適用上，亦即解釋者應該援引何種解釋標準？德國民法第133條及第157條僅提供了不完整的標準供參考，最終仍然要回到歐陸普通法傳統以來所形成的解釋準則。而這些標準間的位階順序或重要性又該如何評價？亦屬下文將探討之難題¹¹。

此外，臺灣的最高法院判決實務上，究竟對於契約解釋的標準或順序為何？本文也試著在眾多判決中，透過類型化方式，釐清基本脈絡供實務界參考。

⁹ *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 1.

¹⁰ 除了用解釋的「標準」外，文獻上還使用其他不同的用字，但均指解釋時可以考量的觀點，而指涉相同之事，包括：解釋的「準則」（*Kanonen*; *canones*）、「因素」（*Elemente*）、「論點」（*Argumente*）、「方法」（*Methoden*）等。Vgl. auch *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 44.

¹¹ *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 2.

貳、法律行為解釋與契約解釋

一、德國法規定之交錯與釐清困難

與臺灣民法對於法律行為解釋只有民法第98條一個條文單獨規定不同，有關於法律行為的解釋，德國民法同時有兩個條文規定並存。德國民法第133條規定（意思表示之解釋）：「解釋意思表示應探求真意，不得拘泥於所用之辭句。」（Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.）同法第157條又規定（契約之解釋）：「解釋契約應該依誠信原則及交易習慣為之。」（Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.）¹²。這兩個條文究竟應該如何區別其法律適用上之關係，德國學說上頗費討論，德國實務上通常將二者並列¹³，但二者之相互關係及實質內涵上則一直有爭論¹⁴。

應先說明者係，思考德國法這兩個條文相互關係的理解，並非比較法上空泛的討論，而是它將會影響到對臺灣法在解釋法律行為時，如何理解或看待臺灣所未規定的德國民法第157條之規範意義？這點，如果我們再回顧一下一開始提到的「巴里島社區案」判決就可以發現，雖然我國沒有德國民法第157條之規定，可是在該

¹² 附帶一提者，德國民法第157條援引誠信原則（德國民法第242條）作為解釋適用內涵的規定，也引發第157條與第242條之關係的討論。一般認為第242條有補充第157條的功能，可以對第157條適用上重要的法律行為之依據及內容進行補充，也就是說第242條規定「應然之標準」（Sollen），第157條則規定「應該要如此進行」（Wollen），但實際運作上二者仍不免混淆。只不過一般不會說是依據民法第242條誠信原則之契約解釋而已。（另參見Reinhard Singer, in: von Staudinger (Hrsg.), Staudinger BGB, 2004, § 133 Rn. 7.）

¹³ 參見BGHZ 47, 75 (78); 124, 64 (67); 146, 280 (284); BGH, NJW 1984, 721 (721); vgl. auch Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 4.

¹⁴ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 29; Reinhard Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 4. Aufl., 2016, Rn. 500.

判決中最高法院同樣宣示：「解釋契約尤須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之」，其實已經將德國民法第157條規定之交易習慣及誠信原則加以實踐運用，即使在下述整理其他判決所形成的案例類型觀察，也可以發現最高法院在不同的判決類型中，重複使用著交易習慣及誠信原則，因此在比較法上確實值得研究德國法對此二者條文競合規定的評價。

從文義上來看，德國民法第133條規範意思表示的解釋，第157條則規範契約之解釋。但實際上單純用解釋的對象是契約或者意思表示來區分二者¹⁵，並沒有實質的正當性，學說上也不認為第133條僅限於適用在單方意思表示之情形，而是認為其與第157條同樣適用於單方、雙方（如契約）與多方之意思表示（如總會決議）及各種法律行為¹⁶，因此時至今日，德國通說及實務均認為二者在適用範圍上相互重疊、彼此補充¹⁷，法律規定對這兩者在體系與用語上所作的區分「並未成功」（*mißglückt* 或者 *verunglückt*）¹⁸，亦無

15 從法律史來看，民法將第133條及第157條分成針對意思表示及契約解釋的兩個條文來規定，其實也並非全是偶然。主要是因為在19世紀當時的學說，「法律行為」還不是「意思表示」與「契約」的上位概念，相反地「法律行為」只是「意思表示」的同義語，因此，針對法律行為的解釋規則通常被認為是一般的解釋規則，而針對契約的解釋規則，則是特別的解釋規則。也因此第157條之前身即民法第一次委員會草案第359條（關於契約解釋），即明白地稱呼該條為第133條的前身即民法第一次委員會草案第73條（關於法律行為解釋）的特別規定（*Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 30.）。

16 *Singer* (Fn. 12), § 133 Rn. 3; *Werner Flume*, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II: Das Rechtsgeschäft, 3. erg. Aufl., 1979, S. 308; *Wolfgang Hefermehl*, in: *Soergel* (Hrsg.), BGB, Bd. II, 13. Aufl., 1999, § 133 Rn. 1; *Arnd Arnold*, in: *Westermann* (Hrsg.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. I, 14. Aufl., 2014, § 133 Rn. 6.

17 BGHZ 47, 75 (78); *Hefermehl* (Fn. 16), § 133 Rn. 1: „Das Anwendungsgebiet des § 133 überschneidet sich mit dem des § 157“ und § 133 Rn. 2: „§ 133 und § 157 ergänzen sich gegenseitig“.

18 *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 29（使用„*mißglückt*“）；*Herbert Roth*, in: von *Staudinger* (Hrsg.), Staudinger BGB, 2016, § 157 Rn. 2（使用„*verunglückt*“）；類似說法並可參見 *Bork* (Fn. 14), Rn. 500; *Dieter Medicus*, Allgemeiner Teil des BGB, 10. Aufl., 2010, Rn. 320; *Flume* (Fn. 16), S. 308.

意義¹⁹，因為解釋意思表示同樣需要考量誠信原則及交易習慣²⁰。法院判決在解釋法律行為時也是將二者規定形式上併用，亦即將民法第133條擴張適用到契約，而將第157條適用範圍擴張到單方意思表示²¹。

其實，大概早在1930年左右，以Karl Larenz的著作為代表的學說²²，就已經認為所有法律行為之解釋，除了第133條外，同時也應該參考第157條，迄今仍為支配性見解。在該書中，Larenz就相當經典地強調這樣的見解。筆者略引述如下佐證並供讀者參照：

如果我們不能單獨將第133條當作探求意思表示在法律上重要意義之標準，那麼顯而易見地就應該將第157條包含進來。……第157條就其文義而言，似乎僅涉及整個契約解釋，但對於個別意思表示之解釋亦得加以參酌，蓋個別表

19 雖然也有見解認為前者應採主觀解釋論，後者應採客觀解釋論。但這樣的說法也沒有意義，因為同樣會遇到主觀解釋與客觀解釋的方法，何者具有優位性的問題。而且此種主觀論的說法，也一再被主張民法第133條應該客觀解釋當事人「真意」的「客觀論」者（objektive Auslegungslehre，例如Danz等）所反對（參見Danz (Fn. 6), S. 14; Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 1.）；同樣地，也被Larenz所嘗試發展、克服主觀及客觀二元分立論，而以探求意思表示在法律上的重要意義，作為二者規定之固有任務的「效力論」（Geltungstheorie）所反駁（參見Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 4對此之詳細說明）。

20 Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 6; Franz Wieacker, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts, JZ 1967, S. 385 (385). Wieacker這篇文章其實是在評論並讚譽下述註22所提到的Larenz在1930年所寫的教授資格論文，該文形容德國民法這兩個條文「只是對於意思表示及契約詮釋學任務的不同面向」，「第133條是「整體性標準」（Kanons der Totalität），而第157條是「客觀化標準」（Kanons der Objektivität）；Flume (Fn. 16), S. 308; Jan Busche, in: Sackner (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl., 2012, § 133 Rn. 17 f.; Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 2; BGH 47, 75 (78); 105, 24 (27); 160, 83 (88).

21 詳參Vogenauer (Fn.7), §§ 133, 157 Rn. 31及該處註107所引帝國法院與聯邦最高法院之判決出處。

22 參見Karl Larenz, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts: Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Willenserklärung, 1930, S. 4-8. 這本書是Larenz在1930年在哥廷根大學所寫的教授資格論文，提出「效力說」（或者後來所衍生的「信賴說」）克服「意思說」與「表示說」的長年爭論。

示行為之解釋與契約之解釋之間，在方法上並沒有差別，同樣地，第133條亦不能單獨作為解釋之基礎。因此，第157條並非如某些學說所認為，僅限於交易行為之解釋，於所有法律行為之解釋中，皆應和第133條一併參酌。(S. 6-7)

如果我們如同今日通說般地理解第133條的意義，那麼該條根本沒有說什麼是「真意」……也就是說，第133條基本上只是一個套套邏輯。(S. 4)

第157條中所提及的二個標準——誠信原則與交易習慣——後者只有在符合誠信原則時，才能加以考量……然而第157條亦未提供一完整之解決方式，而僅提供一形式上之標準，其本身仍須進一步填補。(S. 7)

我們應將此二規定理解為不完整、且因為其各自的片面性而相互限制與補充之規定。(S. 8)

在性質上，第133條及第157條均為「法條化的法律原則」²³，雖然具有法律規範的性質，但只具有一種「指示」(Hinweis)的內涵²⁴或者說二者的實質內涵都是「概括條款式的解釋標準，模糊而有待具體化」²⁵。德國民法立法者一開始就放棄在這兩個條文中提出具體的解釋標準²⁶，誠如其在立法理由中所詳細敘述的²⁷：

²³ 這兩個條文在德國民法典制定之初，其實連總則編與債編的起草者，都反對將法律行為解釋的規則，納入民法典中加以規定。認為那只是重複自然法的規則，多餘而無必要（參見Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 17.）。最有名的是當時von Savigny也質疑：將解釋的規則訂成法條，欠缺法律規範的性質。（並參見Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 26之介紹。）

²⁴ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 26.

²⁵ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 5.

²⁶ 德國立法資料Mot. Bd. I, 155 (Mugdan, Bd. I, 437)引述了普魯士的一般邦法典（Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten）第65條以下，法國民法第1156條以下，義大利民法第1362條以下均有關於一般的解釋規則，但瑞士民法

如同德國普通法時代一樣，幾乎所有最近的立法都含有一系列的解釋規則，一部分是一般性針對意思表示解釋，一部分是限縮在契約。這些立法規定大多數反對嚴格的字義解釋。這些規定都警告並且指出，在探求意思表示時，其他狀況也應該一起考量，包括：交易慣例，當時的語言習慣或意思表示的位置或者說表意人的居住地，先前磋商的過程，綜合其他的約定，法律行為的顯見目的。此類規定，基本上只是無實證法內涵的思維規則；法官只能獲得關於實踐邏輯的教示而已。這樣立法的危險顯然在於：這兩條規定真的被認為是法律條文，而把表達的文字當作是主要標準，因而認為只有法律有特別規定時才可以作不同於文字的理解，進而排除法律中其他所有可能的重要情況。本草案限縮在指示：解釋意思表示時應探求真意，不得拘泥於表達之用語的字面意義。但即使指示這個句子，是否有必要，似乎都還可以存疑。不過至少它給出了一個

及債務法，則並無一般性的解釋規則。相應於此，德國民法乃是刻意不為規定，而只對解釋作出某種指示。

- 27 德國實務家柏林最高法院法官（Kammergerichtsrat）Benno Mugdan（1851-1928）所編纂的五冊德國民法立法資料（Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich），包括第一冊施行法與總則（Band 1. Einführungsgesetz und Allgemeiner Theil）、第二冊債法（Band 2. Recht der Schuldverhältnisse）、第三冊物權法（Band 3. Sachenrecht）、第四冊親屬法（Band 4. Familienrecht）、第五冊繼承法（Band 5. Erbrecht）等，常常被引用作為解釋適用德國民法的重要文件，本文也有多處引用。該書是在1899年德國民法公布生效前出版，原文是古德文花體字，對於研究德國民法立法史者，不僅不易尋找，也不易閱讀。最近德國耶拿大學（Friedrich-Schiller-Universität Jena）法學院的網站已經將該五冊書原文全部掃描成為pdf檔（但仍維持花體字），公布於網頁上供下載（rewi.uni-jena.de），對於研究者取得資料幫助甚大。筆者於2017年暑假期間前往波昂大學（Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn）法學院短期研究時，因參考之文獻需求，再度多次引用此書，特別將此一書籍調取閱讀。由於古德文花體字畢竟不易閱讀，並且發現相關德文文獻引用此書有關德國民法第一次草案第73條之立法資料時，仍過於簡略。考量其涉及我國法第98條立法資料溯源與對應思考，爰特別於本文中將此段落立法資料原文譯錄供讀者參考。

基本規則，而且經驗顯示，商法典第278條也有過相同的規定，並非完全無效果²⁸。

因此，從上開學說及立法資料可以看出，德國法上這兩個條文作為法條規範的意義並不大，也可以說，德國民法即使未有如此之規定，也應該以學說理論上具有共識性的解釋規則來進行解釋²⁹。

不過，即便如同上開學者對於第133條及第157條功能不斷提出質疑，但是單純只是以探求意思表示在法律上之重要意義，作為克服主觀說與客觀說的方法，仍嫌形式而無法解決問題。從實際上來看，當事人想要表達的「真意本身」與當事人實際所作的「客觀表示」，二者是可以區分的，而且從錯誤之意思表示得撤銷之錯誤理論（Irrtumslehre）來看，二者也有區分之必要。

28 Mot. Bd. I, 155 (Mugdan, Bd. I, 437), 原文為„Wie die gemeinrechtlichen Quellen, so enthalten auch fast alle neueren Gesetzgebungen eine Reihe von Auslegungsregeln, theils allgemein für Willenserklärungen, theils in Beschränkung auf Verträge. Die Mehrzahl dieser Regeln richtet sich gegen die strenge Wortauslegung. Es wird vor ihr gewarnt und darauf hingewiesen, dass auch andere Umstände bei der Willenserforschung in Betracht zu ziehen sind, –die Übung des Verkehrs, der Sprachgebrauch zur Zeit oder am Orte der Abgabe der Willensklärung bzw. am Wohnsitze des Erklärenden, der Gang der Vorverhandlungen, der Zusammenhang mit anderen Verabredungen, der offensichtliche Zweck des Rechtsgeschäfts. Vorschriften dieser Art sind im Wesentlichen Denkregeln ohne positiv rechtlich Gehalt; der Richter erhält Belehrungen über praktische Logik. Dabei liegt die Gefahr nahe, daß die Vorschriften für wirkliche Rechtssätze genommen werden und daß der Sinn des gesprochenen Wortes als die Haupttrichterschnur behandelt wird, von der nur insoweit abgewichen werden dürfe, als das Gesetz dies besonders erlaubt habe, während doch die Aufzählung aller möglicherweise maßgebenden Umstände im Gesetze geradezu ausgeschlossen ist. Der Entw. beschränkt sich auf den Hinweis, daß bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften ist. Es kann fraglich erscheinen, ob selbst dieser Satz erforderlich sei. Immerhin giebt (原文即如此拼) er die Grundregel, und die Erfahrung hat gelehrt, daß der gleiche Ausspruch des HGB 278 nicht ohne wohlthätige Folge gewesen ist.“ (此處giebt一字尊重且維持古德文的拼法)。

29 Flume (F. 16), S. 308.

因此，現在德國通說的講法，這兩個條文呈現一種分工的層級狀態，亦即，應該先依第133條規定，就可以推論出當事人「內在真意」的一切外在表徵狀況，針對當事人經驗上的真意作自然的解釋，如果意思與表示互相矛盾，再依第157條作客觀規範上的真意作解釋³⁰。第133條重在提示應探求表意人之真意，從表意者的角度出發，對意思表示進行解釋，而第157條則重在綜合與調和意思表示，並得以透過補充性解釋（*ergänzende Auslegung*）填補契約之漏洞³¹。申言之，第133條主要在對於探求可以適用於個別意思表示、契約、各種法律行為之一般解釋原則，而第157條則特別是針對補充性解釋而發³²。

此時，具有關鍵決定性的是兩個相互交錯的原則：法律行為中的自我決定及自我負責原則，暨交易安全與信賴保護原則。亦即：如果當事人的意思表示符合自我決定與自我負責之精神，且別無其他理由值得保護他造當事人之信賴與交易安全時，則民法第133條的經驗性解釋應該優先，同樣地，如果受領意思表示之對造當事人所認識者，與表意人對其表示所理解者相同，則亦應優先適用經驗性解釋³³。相對地，如果相對人在受領意思表示時並未認識到表意人的真意，意思表示因此可能有撤銷之必要，相對人因而在交易安全上有保護之必要時，則應該同時注意民法第133條禁止作拘泥字

³⁰ *Singer* (Fn. 12), § 133 Rn. 5.

³¹ Vgl. *Arnold* (Fn. 16), § 133 Rn. 6, 20 ff.; Gerda Krüger-Nieland/Richard Zöller, in: Mitglieder des Bundesgerichtshofes (Hrsg.), *Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes (RGRK-BGB)*, Bd. I, 12. Aufl., 1982, § 133 Rn. 11.

³² *Singer* (Fn. 12), § 133 Rn. 3; *Martin Ahrens*, in: Prütting/Wegen/Weinreich (Hrsg.), *BGB Kommentar*, 12. Aufl., 2017, § 133 Rn. 2, 18則特別強調二者主要區別在於：第133條主要適用於無須相對人受領之意思表示（*nicht empfangbedürftige Willenserklärungen*），例如遺贈。第157條主要適用於須相對人受領之意思表示（*empfangbedürftige Willenserklärungen*）。

³³ *Wieacker* (Fn. 20), S. 387.

義之解釋，並依第157條採取客觀規範性解釋³⁴（並參見下文貳、四關於「經驗性解釋」與「規範性解釋」之論述）。

行文至此可以發現，從比較法觀察，我國法上雖然沒有類似德國民法第157條有關契約解釋之規定，似乎也沒有影響，甚至我國法即使有繼受自德國法第133條的民法第98條規定，實益似乎也不高，其究竟應該如何據以適用的疑問，跟德國民法一樣。從我民法第98條既得不出本文一開始提問的解答：法律行為解釋的「目標」為何？也得不出法律行為解釋的標準及其優位順序為何？等問題³⁵。此由下述我實務判決對於法律行為或契約如何解釋，仍然見解分歧，治絲益棼，益可佐證。真正與德國類似的恐怕是：我國透過實務見解的運作，似乎自行解決了經驗性解釋的真意問題，也解決了（客觀的）規範性解釋的問題，更重要的是，反而避開了德國法上開繁雜冗長的爭論過程。

二、立法史上的觀察

就法律繼受的起源來看，德國民法第133條之所以特別強調探求當事人之「真意」，學說上研究指出主要是因為在羅馬法時代，解釋理論主要是針對「遺贈」（Legaten）之死因處分規定而發展出來的（對此，德國民法後來已經在第2147至第2191條對於遺贈（Vermächtnisse）有詳盡規定³⁶，此時無庸考量被遺贈人的保護，因此立遺贈人（被繼承人）的意思（Wille; *voluntas*）自然應該優先於文字。第133條表達出此一重點。但該條規定卻忽略了，將其一般規定化之後，也會涉及生存者之意思，而對其可能有信賴保護之問

³⁴ Flume (Fn. 16), S. 308; BGH 124, 64 (68); BGH NJW 2011, 1666 (1667).

³⁵ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 6.

³⁶ 德國民法第2084條規定迄未改變：「終意處分內容可能有不同解釋者，有疑義時，應以可使該項處分有效果之解釋優先。」（Lässt der Inhalt einer letztwilligen Verfügung verschiedene Auslegungen zu, so ist im Zweifel diejenige Auslegung vorzuziehen, bei welcher die Verfügung Erfolg haben kann.）

題³⁷。至於第157條會以「契約」作為規範重點，則是一種無意的巧合（unbeabsichtigte Reminiszenz），因為該條之前身乃是德國民法第一草案第359條，該條本來是規定在債法中，用以規範基於債之契約而生義務，後來在第二次委員會才被放寬成為通則性的適用規定³⁸。

另外，從德國民法第133條的立法史來看，據學者研究指出，該條主要是繼受自1861年的德國一般商法典（Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch，以下均簡稱ADHGB）第278條，該條文字原規定「法官在判斷與解釋商事行為時，應探求訂約者之意思，不得拘泥於所用之詞句」³⁹，該條規定主要是適用於至少一方當事人為商人的所有交易行為。而該條規定據研究則又可溯源繼受自1857年普魯士國商法典草案（Entwurf eines Handelsgesetzbuchs für die Preussischen Staaten）第214條第1項（該項文字稍有不同地強調「法官在解釋契約與判斷商事行為時，應探求訂約者之意思，不得拘泥於所用之詞句」）。

之所以要特別強調「探求訂約者之真意」，主要也是因為商事行為的特性所在，因為當時的商事法庭法官是可能由商人擔任的，而當時的商人很喜歡對契約作文字的字面解釋，因此有必要提醒法官注意避免此事；此外，由於當時商業交易的迅速性，常使得商人並未謹慎地選擇其訂約時的用語，因而不能以未經謹慎選擇的用字來代替當事人訂約的真意；最後是，因為當時普魯士的一般邦法典（Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, Preuß. ALR）第65條第1項第4款有明文規定，法官理解法律行為「應依文字及符

37 Vgl. *Medicus* (Fn. 18), Rn. 320.

38 Vgl. *Flume* (Fn. 16), S. 308之詳細說明。

39 原文為„Bei Beurtheilung und Auslegung der Handelsgeschäfte hat der Richter den Willen der Kontrahenten zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdruckes zu haften.“ —筆者按：此處德文拼字是尊重並維持當時德文的拼法。

號的通常意義……探求明示的意思表示之意義」，故上開1857年普魯士國商法典草案及1861年的德國一般商法典（ADHGB）有必要針對民法典應受文字拘束的規定，在商法典中作出相反的宣示⁴⁰。德國民法典制定時的第一次委員會⁴¹認為上開1861年的德國一般商法典（ADHGB）第278條，並非無用，因而在第一次草案第73條將「商事行為」改為「意思表示」後，訂為後來的第133條。但有趣的是，後來德國商法典反而以民法典已經有第133條規定為由，不必重覆規定而未將德國一般商法典（ADHGB）第278條繼受於後來的德國商法典中⁴²。

至於德國民法第157條規定，雖然在1861年的德國一般商法典（ADHGB）僅接在第278條之後的第279條有類似規定，強調商事行為之解釋，應考量「商業交易中適用之習慣與慣例」，但是該條並未成為第157條的前身，而是幾乎一字不變地成為現行德國商法（HGB）第346條的內容⁴³。相反地，第157條之產生則與德國民法第242條有關誠信原則之規定息息相關。在第一次民法草案中，立法者參考了德列斯登草案（Dresdner Entwurf）第150條的文字規定⁴⁴，而在草案第359條規定了：「基於契約而生的債之關係，其拘束力來自於依法律、交易習慣以及考量誠實信用原則而作成之契約

40 詳見Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 18 ff.

41 德國民法典編纂主要經過兩次委員會，提出過兩次草案（1881年第一次委員會，1887年公布第一次草案；1890年第二次委員會，1895年公布第二次草案），其中Windscheid兩次均有參與，特別對第一次草案的精神與形式有重大影響；Albert Gebhard是實務家，負責起草總則部分。簡要中文文獻可參見Franz Wieacker著，陳愛娥、黃建輝譯，近代私法史，頁433以下（2004年）。

42 Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 23.

43 現行德國商法第346條規定：「商人間的行為或不行為之意義與效力，均應考量商業交易中適用之習慣與慣例。」（Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehre geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.）

44 Vgl. Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 24 Fn. 62. 引述了立法理由中列舉的參考立法例，但的確就是沒有列出德國一般商法典（ADHGB）第279條。

規定內容與本質」。這是因為第一次委員會想要特別強調誠信原則在商業交易中的重要意義，並且要將草案第359條作為一般的解釋原則。雖然立法過程有人批評與民法第242條誠信原則之規定重複而無必要，但後來第二次委員會認為該條主要是特別針對債之關係的履行方式所作的規定，至於誠信原則則不僅在於確定債之內容，也包括其他所有契約關係，應屬於一般總則性之規定，因此二者並不相同⁴⁵。

茲略圖示其發展如下，以求明瞭：

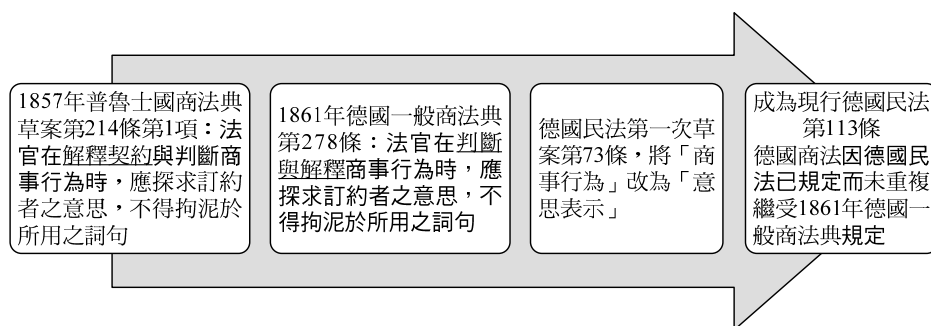


圖2-1 德國民法第133條之發展脈絡

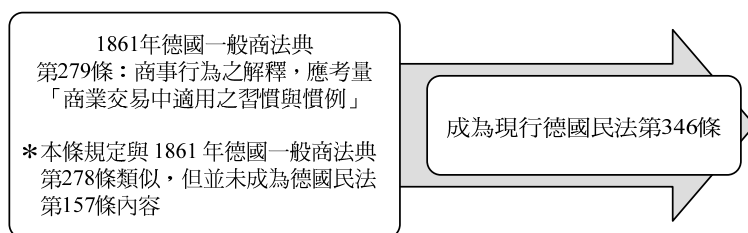


圖2-2 德國民法第157條之發展插曲

45 Vgl. Prot. Bd. II, 1251 f. (Mugdan, Bd. II, 522); Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 26.

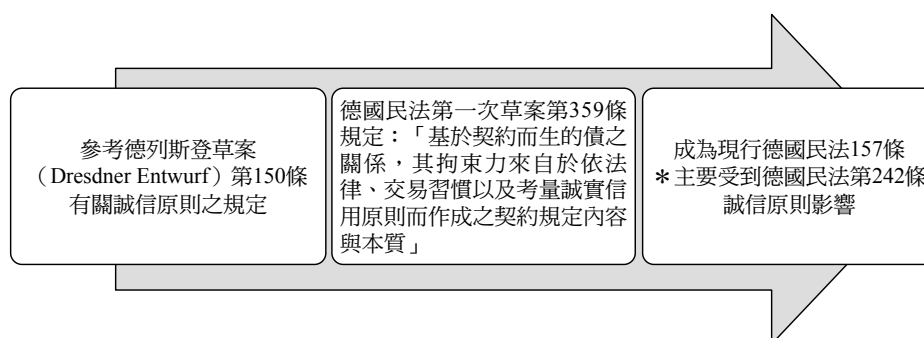


圖2-3 德國民法第157條之發展脈絡

圖2 德國民法第133條及第157條之歷史發展

資料來源：作者自製。

三、法律行為解釋之目標

(一) 意思說vs表示說？

19世紀下半以來有關法律行為解釋探討的核心問題就一直是：解釋的目標（目的）究竟是在確定表意人的主觀意思，抑或在確定該主觀意思以外，該表示本身獨立客觀之意義？

「解釋的目標」為何，最早是由自然法論者Christian Thomasius所提出，強調解釋的主觀說，認為解釋的目標在於探求文本的起草者所要賦予其文字的真正意義⁴⁶。解釋的最終目的因此在於探求表示者之意圖。這背後的哲學基礎主要來自斯多葛哲學及後蘇格拉底

⁴⁶ Stefan Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent: Eine vergleichende Untersuchung der Rechtsprechung und ihrer historischen Grundlagen, Bd. I, 2001, S. 436.

時代的道德神學，其思想認為任何一個表示的法律效果都來自於道德上自我負責的個人的意志，他不可以自我矛盾⁴⁷。

一直到「意思表示」成為法律行為論的核心概念時，主觀論與客觀論的爭議才被引進到現代法學的領域中，因而對應於自然法論的概念將此種主觀說稱為「意思說」(Willenstheorie)。主觀論與客觀論的法學爭論也就對應探尋：究竟產生法律效果的是意思表示兩個要素中的內在意思，還是對外的表示？後者被對應稱為「表示說」(Erklärungstheorie)。

如果是前者，則解釋之目的就在探求內在的真正意思。反之，如果是後者，則解釋的目的應該就在於確定意思表示的文字所表達出來的意義⁴⁸。更重要的是，表示說並不是要探求意思表示的相對人(受領者)事實上所理解的意義，而是要探求如果處在相對人的地位上，一個「理性人」⁴⁹(ein vernünftiger Mensch)、「平均人」

47 Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 34.

48 Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 35.

49 理性人的客觀標準也為其後的國際公約所繼受，參見CISG（聯合國國際貨物買賣公約第8條或UN-Kaufrecht）：「（第1項）一方當事人之陳述及其他行為應按照其作出者的意思來解釋，如果他方當事人知道或不可能不知道該意思時。（第2項）前項規定無法適用時，一方當事人陳述及其他行為應該依照處於相同情況下與另一方當事人同類型的理性人之理解來解釋。（第3項）為了確定一方當事人的意思或一個理性人應該有的觀點，應考慮與案件相關的一切重要情況，特別是當事人間協商情況、當事人間確立的習慣作法、慣例以及當事人之後的行為。（粗體字為筆者所自行強調。）該條英文為：「(1) For the purposes of this Convention statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to his intent where the other party knew or could not have been unaware what that intent was. (2) If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances (3) In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case including the negotiations, any practices which the parties have established between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties.」德文為：「(1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens sind Erklärungen und das sonstige Verhalten einer Partei nach deren Willen

(Normalmenschen) 或者「一般社會大眾」(Allgemeinheit) 必然會作的理解為何？因此，解釋者的任務不是描述性地，而是評價性地探究意思表示的客觀意義⁵⁰。也因為此時同時在保護相對人對於意思表示之通常意義的正當信賴，因此嗣後也有從這個角度稱此說為「信賴說」(Vertrauensstheorie) 者⁵¹。

auszulegen, wenn die andere Partei diesen Willen kannte oder darüber nicht in Unkenntnis sein konnte. (2) Ist Absatz 1 nicht anwendbar, so sind Erklärungen und das sonstige Verhalten einer Partei so auszulegen, wie eine vernünftige Person der gleichen Art wie die andere Partei sie unter den gleichen Umständen aufgefaßt hätte. (3) Um den Willen einer Partei oder die Auffassung festzustellen, die eine vernünftige Person gehabt hätte, sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, insbesondere die Verhandlungen zwischen den Parteien, die zwischen ihnen entstandenen Gepflogenheiten, die Gebräuche und das spätere Verhalten der Parteien.」該條的德文註釋書Alexander Lüderitz, in: Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. XIII: Schuldrechtliche Nebengesetze 2. CISG, 13. Aufl., 2000, Art. 8特別強調，第1項規範表意人意思優先於其所為之表示，第2項依據具體個別情形決定受領之相對人的理解視域而解釋，第3項規定解釋之素材並無限制 (Rn.1)。而如同本文下述地，其中第一項就是規定「經驗性解釋」，探求表意人事實上、經驗上的真意，亦即：如果表意人的表示，對相對人而言幾近明確可知，則即使明知表示錯誤，亦屬無害，並引述著名的「用語錯誤無害真意原則」(*falsa demonstratio non nocet*) (Rn. 2及Rn. 4)。而該條第2項則是規定「規範性解釋」，強調「如果事實上表意人的主觀真意與受領之相對人理解不同，則重要地依據第2項，視一個理性的受領者在具體情況下如何理解該意思表示。用德文的用語就是符合客觀相對人理解視域之標準……以他方當事人作為『理性人』可以期待他對該意思表示之內容所做的理解」(Rn. 5)。並參見Manfred Wolf/Jörg Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 11. Aufl., 2016, § 35 Rn. 26及該處註46也特別提及CISG這個條文規定的重要性。又PICC (國際商事契約通則) 第4.1 (2)、4.2 (2)，PECL (歐洲契約法原則) 第5: 101 (3)，DCFR Art. II-8: 101 ff.等規範的解釋規則內容大致相同。此等國際契約文件就此規定之整理，參見李其陸，法律行為解釋之理論與實務——以契約之解釋為中心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁63-78 (2015年)。有關德國法與上開國際文件在解釋方法上之比較，並製表詳細比較。

⁵⁰ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 35. 學說上有稱此為「規範上的共識」(ein normativer Konsens) 者 (參見Ernst A. Kramer, Grundfragen der vertraglichen Einigung: Konsens, Dissens und Erklärungsirrtum als dogmatische Probleme des österreichischen, schweizerischen und deutschen Vertragsrechts, 1972, S. 60 ff.)。但此限於有相對人的交易行為，無相對人的遺囑行為則仍採探求立遺囑人真意的主觀說作為其解釋之目的。

⁵¹ 參見Heinrich Titze, Rechtsgeschäft, in: Schlegelberger (Hrsg.), Rechtsvergleichendes Handwörterbuch, Bd. V, 1936, S. 790; Roth (Fn. 18), Vorbem zu 116-144 Rn. 14-25.

(二) 客觀說勝出

兩說的爭論發展到19世紀末，表示說就逐漸占上風。因為主觀說強調表意人僅對其主觀意思負責，固然最完美地實現了私法上個人的意思自主，但在法政策的典範變遷上，客觀說透過對於正當信賴意思表示者之保護，而強調個人的社會拘束與義務，終究較為符合法官理性與正當的感受，而獲得多數人接受。

學說上對於客觀說的勝出，有認為在評價上至少反應了私法史上四個重要的思想變遷的特徵⁵²：1. 國家觀的變遷：符合了從19世紀自由的國家觀過渡到當代的社會國模式的現象；2. 經濟觀的變遷：反應了從個人主義式地、自給自足式的個人結社，過渡到較強的工業化、分工式地建構典型社會而注重對人的生存照顧之公司；3. 訴訟觀的變遷：顯示出法官的權利加大，法官不再只是制定法的僕人，更不是當事人意思的僕人；4. 哲學觀的變遷：出現「背離法實證主義」(Abkehr vom Rechtspositivismus)的現象，法與道德、存在(當事人事實上的意思)與當為(當事人理想的意思)之截然劃分，逐漸被揚棄。隨之而來的是私法負載著倫理、實質化，整個法文化聯結濃厚的價值關聯(Wertbezogenheit)。

然而，一如法律解釋，法律行為的解釋在真正的實現上，也是呈現一種主觀說與客觀說結合的解釋論(結合說或者折衷說)。即便以德國民法編纂參與者Bernhard Windscheid為例，他明顯地是主觀說的擁護者，認為解釋的任務固然在於確定意思的內容，但同時也強調這個意思是「被表示的意思」(erklärter Wille)，通常必須連同當時客觀上伴隨的狀況才能探求該意思，當表意人的意思只是被視為一種真意的表達時，表意人的意圖所能影響的就只是法律效果

⁵² 這是借用Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 36的講法。但1.至4.的小標題則為本文所自行加上。

而言⁵³。Heinrich Dernburg也說：「解釋……試圖從法律行為訂立當時的整體以及依當時可以認知的目的，去探求當事人的意思。⁵⁴」

雖然如前所述地，德國民法第133條的前身亦即1861年的德國一般商法典（ADHGB）第278條的條文文字規定「法官在判斷與解釋商事行為時，應探求訂約者之意思，不得拘泥於所用之詞句」，確實使用「意思」二字，而德國民法編纂者即參與主導第一次委員會總則部分的Albert Gebhard⁵⁵，在立法理由中自己確實也多次承認偏好意思說⁵⁶，並且在立法理由中反駁客觀說謂：「解釋契約時不依訂約者所說的真正意義，而依他方當事人按其當時的狀況對該意思的理解，這種觀點根本站不住腳。否則意思主義以及契約是本於當事人意思表示一致而成立的基本思想，將被破壞殆盡。⁵⁷」因而立法者直接在立法理由中擷取了主觀說擁護者Windscheid在其Pandekten教科書中反駁客觀說的一段話，進而在民法草案第73條中明白使用探求「真意」（wirklicher Wille）二字，用字比德國一般商法典（ADHGB）第278條用「意思」而已，更為明確。這個「真意」，立法者的意思就是「心理的」或「內心的」意思⁵⁸，而有意與客觀說強調的「被表示的意思」（*erklärter Wille*）作區分。第二次委員會會議亦不採客觀說，進而將該草案定為現行的第133條條文。

53 *Bernhard Windscheid*, Wille und Willenserklärung: Eine Studie, AcP 63 (1880), S. 72 (76 f.); *Bernhard Windscheid*, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. I, 2. Aufl., 1867, S. 206, 207. 引自 *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 37.

54 *Heinrich Dernburg*, Pandekten, Bd. I, 4. Aufl., Berlin 1894, § 123, 291, 轉引自 *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 38.

55 德國民法典編纂過程主要經過兩次委員會，提出過兩次草案（1881年第一次委員會，1887年公布第一次草案；1890年第二次委員會，1895年公布第二次草案），Albert Gebhard是實務家，負責起草總則部分。參見註41之說明。

56 Mot. Bd. I, 155 (Mugdan, Bd. I, 437 f.); Mot. Bd. V, 44 f. (Mugdan, Bd. V, 23 f.).

57 Mot. Bd. I, 155 (Mugdan, Bd. I, 437 f.)，並參見 *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 38.

58 *Vogenauer* (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 38.

(三) 法官確定「真正被表示的意思」

但是，第133條公布生效的結果並不代表主觀說獲得最後勝利。相反地，德國學說以及最高法院的判決（包括帝國法院及其後延續其傳統的聯邦最高法院），從該條自1900年生效時起，就立刻把這條著名的（但也被認為是聲名狼藉的）條文規定，予以客觀化解釋適用⁵⁹。除了將民法第157條也擴張適用到意思表示，而將誠信原則作為規範上確定一個理性、正當思考的相對人應該會如何理解該意思表示之規則外，並且將第133條之「真意」解為非指表意人內心的意思，而是指「真正被表示之意思」（**wirklich erklärter Wille**），也就是等同於「表示之內容」（**Erklärungsinhalt**），要探究的是「意思表示的真正內容」（**wahrer Inhalt der Erklärung**）⁶⁰。法官在法律行為的解釋過程成為社會的工程師，探求當事人的真意，事實上是指涉法律行為的內容，為法官在考量案件的所有狀況，在經濟上認為具有合目的性與正當者而言⁶¹。此時，不僅僅只是「假設的當事人意思」（**hypothetischer Wille der Parteien**）而已，更進一步說，可以說是「法官以理想的假設的當事人意思之名，所作的意思表示之內容確定」⁶²（**richterliche Inhaltsbestimmung unter Berufung auf den hypothetischen Willen einer Idealpartei**）。當Larenz在1930年宣示要以一個寬闊的思想，揚棄主觀解釋論與客觀解釋論二元對立時，他對於解釋的目標也不再與當事人之意思有關了⁶³。這也就是下文所說的規範性解釋之問題了。

⁵⁹ Vögenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 39.

⁶⁰ Vögenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 39.

⁶¹ RGZ 68, 126 (128); 119, 21 (24 f.); BGHZ 47, 75 (78); 103, 275 (280).

⁶² Wolfgang Kilian, Zur Auslegung zivilrechtlicher Verträge, in: Koch (Hrsg.), Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, 1976, S. 271 (276 f.).

⁶³ Vögenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 40.

解釋的目標剩下的只是：在何種程度內，例外地應該在客觀說以外注意當事人內心的主觀意思。此點，通說認為遺囑等無相對人的意思表示，仍然應該探求當事人內心的真意。

準上所述，從今日的角度來看，德國民法第133條的文字規定容易使人誤解應探求當事人單純的真意。但單純真意並不足夠，真意已經被表達出來，因此要探求的應該是表意人對該意思作表示時所賦予的意義為何，以及表意人所理解的意義。因此，解釋的對象應非單純的內在真意，而是發生效力之被客觀化的意思。準此，第133條僅係指，「重要的不是外部文字，而是已經對外發生效力的表示之意義為何？」⁶⁴而已！

（四）利益衡量代替解釋的目標

最近，更有學說強調，當愈是遵循客觀說而以之作為法律解釋之目標時，法律上要保護的相對人範圍愈大，愈難個別商訂法律行為的約定內容。因此有學者認為只能透過個案的案例群來決定（Fallgruppen-Kasuistik），此時「法律行為的解釋將是不斷地具體衡量對立的當事人間之利益的判斷過程」。此時個別意思表示的構成要件事實應該依其所呈現典型的利益狀態，以案例群（gruppenweise）的方式來決定，何種程度的相互理解至少是可以受到當事人期待的，此時可能有時客觀解釋重要，有時主觀解釋重要⁶⁵。因而逐漸也有學說接受，認為不再有一個統一的解釋目標，而應該依照意思表示的種類作個別的利益評價，「解釋的目標不再是實現一個理論，而是獲得一個理性的結論」⁶⁶。此點，特別在下文中對應臺灣法院實務判決對於契約解釋的態度，益顯得有趣！

⁶⁴ Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 1.

⁶⁵ 主要參見Ludwig Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 1935, S. 154 ff.

⁶⁶ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 42.

當對法律解釋的目標觀察發展至此，不僅使吾人重新想起Karl Larenz在前曾引述1930年的教授資格論文「法律行為之解釋方法」前言中所說的：「解釋意思表示時，意思與表示的關係、主觀解釋與客觀解釋的關係，是有限於個別實證部門法，且不可能被完全解決的『法學上永恆的難題』，也是法學上『永恆的任務』⁶⁷」時，更可以看出他對這個無解難題的洞見。

（五）臺灣民法第98條規定的現況與反思

1. 探求「當事人真意」造成的適用上混亂

對於德國民法第133條及第157條之交錯關係及其在立法史上之觀察，可以發現繼受自德國民法第133條的臺灣民法第98條，即使沒有德國民法第157條的類似規定，也有同樣在適用上的混亂與困擾。

按臺灣民法第98條規定：「解釋意思表示應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句」，乃有關意思表示之內容不清或缺漏如何解釋之基本規定。但是意思表示究竟應該如何解釋，特別是在當事人的「真意」與所用之「辭句」不一致時，究竟應該以「內在真意」或者「外在辭句」為優先？這個條文規定在文義上就不清楚。

最高法院19年上字第58號民事判例宣示謂：「解釋當事人之契約，應於文義上及論理上詳為推求，不得拘泥字面，致失當時立約之真意。⁶⁸」，至於如何推求「立約當時之真意」⁶⁹，除了該判例強

⁶⁷ Larenz (Fn. 22), Vorwort.

⁶⁸ 例如最高法院28年上字第598號民事判例即強調，當事人以不動產「設定之書面稱為質權而不稱抵押權，亦不得拘泥於所用之辭句，即謂非屬抵押權之設定」。

⁶⁹ 強調立約當時真意者，最高法院19年上字第453號、39年台上字第1053號、49年台上字第303號等民事判例。

調應推求文義「及論理」外，後續判例進一步補充尚包括應該：「通觀全文」⁷⁰、考量「立約當時之事實」⁷¹（過去之事實⁷²）或「立約當時之情形」⁷³、考量「其他一切證據資料」⁷⁴，以避免拘泥文字致失真意。（對照德國法之爭論，以下暫時稱此為「意思說」。）

但最高法院17年上字第1118號民事判例則謂：「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨文字而更為曲解。」（對照德國法之爭論，以下暫時稱此為「表示說」。）

上開兩種判例論述之角度：「詳為推求契約文義……不得拘泥字面，致失……真意」（「意思說」）與「契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求」（「表示說」），究竟應該如何區分？適用上有無先後？

延續著判例的兩種角度，其後之法院判決亦呈現兩種不同的發展。

（1）意思說？

表現出意思說，而在教科書中常被引用的最高法院65年度台上字第2135號判決⁷⁵：「第按解釋契約，應探求當事人立約時之真意，而於文義上及論理上詳為推求當事人之真意如何？又應斟酌訂立契約當時及過去之事實，其經濟目的及交易上之習慣，而本於經驗法則，基於誠實信用原則而為判斷。」

⁷⁰ 最高法院18年上字第1727號民事判例。

⁷¹ 最高法院19年上字第28號民事判例。

⁷² 最高法院19年上字第453號、39年台上字第1053號民事判例。

⁷³ 最高法院18年上字第1727號民事判例。

⁷⁴ 最高法院19年上字第28號、第453號及39年台上字第1053號等民事判例。

⁷⁵ 司法院法學資料檢索系統無法查得此判決全文，出處為法令月刊，30卷2期，頁20，轉引自王澤鑑（註3），頁453。

最高法院88年度台上字第972號民事判決：「按解釋契約，應探求當事人立約時之真意，而探求當事人之真意，本應通觀契約全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值等作全般之觀察。」

最高法院85年度台上字第2585號民事判決：「查解釋當事人之契約，應於文義上及論理上詳為推求，以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字面，致失當時立約之真意。兩造於買賣契約約定『停車場車位另行銷售，各戶不須負擔其坪數』等語。上訴人主張：此等文字係約定由上訴人保有停車位之專用權，購買停車位者，取得較多之地下室所有權應有部分，方得使用特定之停車位，未買受停車位者不得使用等語。被上訴人則辯稱：依此項約定，買得停車位者固得使用特定停車位，但其餘未出售之停車位仍應由全體住戶使用等語。兩造對於此項約定之真意既有爭執，法院自應探求當事人訂約之真意，而為判斷……」

最近最高法院101年度台上字第2100號民事判決更謂：「按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，作全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。」

(2) 表示說？

代表文義說，而強調解釋契約不得反捨所用辭句而他求者，例如最高法院86年度台上字第3042號民事判決：「查解釋意思表示，固須探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，但所用之辭句業

已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨所用之辭句而更為曲解。⁷⁶」

最高法院97年度台上字第1122號民事判決之原審採表示說，謂：「解釋意思表示，固須探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，但所用之辭句業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨所用之辭句而更為曲解。上訴人於第一審起訴主張：被上訴人之被繼承人劉春桃偽稱知悉有一幢設定抵押之樓房，現正由法院要低價拍賣為由，誘使伊出資新台幣（下同）四百萬元，與其合夥買下該屋云云，被上訴人亦不否認劉春桃與上訴人間成立合夥關係，兩造就上訴人與劉春桃間成立合資或合夥契約等情，並無異詞……合夥為諾成契約，亦非要式行為，除當事人間有以作成書據為成立要件之約定外，苟二人以上已為互相出資以經營共同事業之約定，雖未訂立書據，其合夥亦屬成立。上訴人因與劉春桃合資購買法拍屋方匯款四百萬元，二人間有合資關係之契約，性質上屬合資購屋之合夥契約，至為明確，應依其所言合夥之法律關係，無待別事探求。」但卻遭最高法院廢棄，廢棄理由則謂：「惟解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥使用之文句致失真意。本件上訴人於第一審起訴時主張：劉春桃偽稱知悉有一幢設定抵押之樓房，現正由法院要低價拍賣為由，誘使伊出資四百萬元，與其合夥買下該屋云云，被上訴人並未加爭執，固為原審所確定。但法院就當事人主張之事實，如何適用法律，原不受當事人

76 同此見解尚有：最高法院96年度台上字第1577號民事判決：「按解釋意思表示，固須探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，但所用之辭句業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨所用之辭句而更為曲解。查上訴人甲○○○就交付系爭款項之事實，業已提出匯款單……三紙為證……，而該匯款單上送金目的欄復載明『親族の貸付』等文字，此等文字究於何種情況下所記載？有無其他佐證？攸關甲○○○得否依消費借貸之法律關係請求乙○○○給付該借款，能否猶謂甲○○○並未舉證其主張丁○○○與被上訴人乙○○○間有借款之合意及事實？尚非無疑。」

法律上陳述之拘束。經查民法之合夥係指二人以上互約出資以經營共同事業，分享其營業所生之利益及分擔所生損失之契約，觀諸民法第六百六十七條第一項之規定自明，是合夥應就如何出資及共同事業之經營為確實之約定始足當之，倘僅單純出資取得財產而未約定經營共同事業者，縱將來可獲得相當之利益，亦僅屬合資或共同出資之無名契約，與民法所定之合夥尚屬有間。則本件原審就上訴人匯款與劉春桃購買法拍屋，有無就如何經營共同事業及分配盈虧為合致之意思表示，胥未調查審認，徒以上訴人既稱係合夥之法律關係，即無待別事探求為由，遽為上訴人不利之論斷，不免速斷。」

印證上開兩種判例與判決的論證方式，足見最高法院對於臺灣民法第98條的規定一直處於主觀當事人真意（意思說）與客觀契約文字（表示說）之間，究應如何探求的擺盪之間，並未一致。

2. 避開解釋目標之爭

如果從法制史上尋找這個條文的繼受，或可以供參考。在大清民律草案第200條規定：「解釋意思表示不得拘泥語言、字句，須探究其真意。⁷⁷」民國民律草案第134條規定：「解釋意思表示，應探究其真意，不得拘泥辭句。」這兩個草案條文如果再對照於前述德國民法第133條之文字，其實忠實地翻譯應為：「解釋意思表示時應探求真意，不得拘泥於表達之用語的字面意義」，均未有探求之對象為「當事人」之真意之字眼。可見立法者當時在遙譯德國民法第133條條文，成為現行臺灣民法第98條時⁷⁸，自行加上了不必要的

77 現行民法第98條的立法理由謂：「查民律草案第二百條理由謂意思表示，其意義往往有欠明瞭者，應將不甚明瞭之處解釋之。但應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，致失真意。此本條所由設也。」但其實民律草案第200條也沒有應探求「當事人」之真意之字樣。

78 臺灣此一條文除係參考自前揭德國法第133條之立法例外，類似法律行為解釋之規定尚有法國民法第1156條（解釋契約應探求當事人共同之意思，不得拘泥於所用詞句之文理意義），瑞士債務法18條第1項（判斷契約應就其方式及內

探求「當事人」真意的「當事人」字眼，造成臺灣法在解釋上隨其文字，更陷入主觀說與客觀說的爭論中。

筆者認為，基於下列理由，臺灣民法第98條應該參考上開民律草案及德國法條文之規定，直接讀成解釋意思表示應探求「真正被表示之意思」，省去令人困擾與不解的「當事人之真意」。亦即：第一、臺灣民法並無如同德國必須強調主觀說（探求當事人真意）之背景，自無庸特別強調；第二、臺灣民法公布於1929年，當時德國主觀說與客觀說之爭論已經由客觀說居於學說及實務之通說迄今，主觀說因其不可行與不合實際某程度已被揚棄，臺灣民法與學說自無庸再以之自我攪擾，應跳脫主客爭論的窠臼。

臺灣學說，對於此一條文的解釋，基本上也是採取客觀解釋，誠如王澤鑑教授所言：「民法第98條規定……意思表示解釋之目的乃在探求當事人之『真意』。問題在於『當事人之真意』，究指何而言。……意思表示解釋所要探求的真意，應依意思表示的種類（如

容，注意當事人一致之真實意思，不得著重於當事人誤解或隱蔽真意所用之不當文字或語句）〔對法國民法及瑞士債務法關於此一相關規定之介紹，中文文獻亦可參見龍衛球，民法總論，頁551-553（2000年）〕，日本則並無類似條文，僅賴學者解釋（鄭玉波教授所列之日本法類似條文僅該國民法第92條「有與法令中公共秩序無關的規定相異之習慣存在，而可認為法律行為之當事人，有依習慣之意思者，從其習慣」，但顯與意思表示之解釋無關）。參見洪遜欣，中國民法總則，修訂再版，頁312、316註1（1987年）；史尚寬（註1），頁414；鄭玉波、黃宗樂，民法總則，修訂9版，頁292註28（2004年），該處所列外國立法例。中國大陸民法通則原本沒有類似規定，而係規定在合同法第125條「（第1款）當事人對合同條款的理解有爭議的，應當按照合同所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。（第2款）合同文本採用兩種以上文字訂立並約定具有同等效力的，對各文本使用的詞句推定具有相同的含義。各文本使用的詞句不一致的，應當根據合同的目的予以解釋。」於2017年3月15日通過、同年10月1日生效施行之民法總則第142條已增訂：「（第1款）有相對人的意思表示的解釋，應當按照所使用的詞句，結合相關條款、行為的性質和目的、習慣以及誠信原則，確定意思表示的含義。（第2款）無相對人的意思表示的解釋，不能完全拘泥於所使用的詞句，而應當結合相關條款、行為的性質和目的、習慣以及誠信原則，確定行為人的真實意思。」

有無相對人)，及解釋的層次（闡釋性解釋及補充解釋）而有不同：在有相對人的意思表示，應顧及相對人了解的可能性，以探求表示行為的客觀意義；在補充解釋，其所探求者，乃所謂『假設的當事人的意思』，以補充意思表示（尤其是契約）內容的不備。⁷⁹」洪遜欣先生謂：「所謂真意，指當事人依意思表示所企圖之趣旨而言，亦可謂為表示上之效果意思，並非內心的效果意思之謂。⁸⁰」鄭玉波先生亦謂：「所謂真意乃指表示之真正意思，並非當事人內心之真意……此之所謂探求真意者，重在探求當事人所為意思表示自身之真意，至其內部所保留之真意如何，則非所問。⁸¹」可資佐證。

值得注意者係，最高法院最近也開始表示此種見解，該院102年度台上字第288號民事判決謂：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八條定有明文。所稱真意，乃指表示之真正意思而言，非謂當事人內心之真意。是以意思表示解釋之客體，為當事人已經表示於外部之效果意思，而非其內心蘊藏之意思。」

在此種前提下，上開意思說與表示說的實務見解，其實都只是在重複下述法律行為解釋中，有關於闡釋性解釋的方法，而指出法律行為的解釋標準除了文字（字義）以外，還有多少其他伴隨的外部狀況應該一起作為斟酌之要素（或標準）而已。只不過，接下來在臺灣法上有關法律行為解釋的問題，就在於：法律行為解釋標準為何？應該如何處理除了字義以外，臺灣判決實務上解釋標準日益龐雜繁複的問題（參見下述參、四對於臺灣契約解釋類型之觀察）！

79 王澤鑑（註3），頁451。粗體字為筆者所自行加上強調。

80 洪遜欣（註78），頁312。

81 鄭玉波、黃宗樂（註78），頁292。

四、法律行為解釋之三階段：經驗性解釋、闡釋性解釋與補充性解釋

（一）解釋之種類

德國法上有關於契約解釋之分類（種類），學說或實務上使用的用語不完全相同。但是參考多數學說大致上可以歸納分成三大類或者三個階段，亦即經驗性解釋、闡釋性解釋及補充性解釋⁸²。

如前所述地依德國民法第133條，先以經驗性解釋（或者自然的解釋⁸³，或直接的解釋⁸⁴，或簡單的解釋⁸⁵，或固有的解釋⁸⁶）從表意人的主觀角度，探究「表意人」為該意思表示的事實上「真意」為何？

如果表意人的真意未被相對人認知而「一致」理解，則依德國民法第157條規定，在對相對人就該被表示之意思的客觀意義予以信賴保護之觀點下，則必須進入「規範性解釋」（normative

82 Bork (Fn. 14), Rn. 511 ff.; Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 3-5; Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 22; Manfred Wolf, in: Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. II, 13. Aufl., 1999, § 157 Rn. 29 ff., 103 ff.; Busche (Fn. 20), § 133 Rn. 5. 少數說法：Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 66 ff. 則不用此三階段，而類比於法律解釋的三階段，用「解釋」、「補充」與「修正」，詳見下述註113之說明，不過通說認為「補充性解釋」這個概念是根據法律行為為對象而來，當事人之意思仍屬重要，不能完全與對法律解釋等同看待，因此認為補充性解釋性質上還是解釋，所以並不贊同Neuner的批評（參見Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 4.）。另外Arnold (Fn. 16), § 133 Rn. 14-23則使用「簡單的（闡明性）解釋」作為上位概念來涵括「自然的解釋」與「規範性解釋」，而與第三種「補充性解釋」相對。

83 „natürliche Auslegung“：這主要是Bork (Fn. 14), Rn. 511 ff. 喜好使用的用語。

84 „unmittelbare Auslegung“：這是德國聯邦最高法院曾經使用的用語，參見BGH NJW-RR 1995, 833 (834); NJW 1975, 1314 (1314); Holger Wendtland, in: Bamberger/Roth (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl., 2012, § 157 Rn. 7.

85 „einfache Auslegung“：這是Busche (Fn. 20), § 133 Rn. 5的用語。

86 „eigentliche Auslegung“：這是Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 3-5的用語，但其意涵似乎又包括本文分類的「經驗性解釋」與「闡釋性解釋」（客觀規範性解釋），而將其與「補充性解釋」相對。

Auslegung) 範疇，以「評價上的觀察方式」進行探究⁸⁷。在「規範性解釋」這個上位概念下，先透過「闡釋性解釋」⁸⁸ (erläuternde Auslegung) 之方法探求當事人「可能的意思」(der mutmaßliche Wille)。此項闡釋性解釋之方法應該考量的因素甚多，主要將在下文參、二有關於法律行為解釋之標準中對應深入討論。

如果透過闡釋性解釋發現某一個爭議問題點，當事人並沒有特別約定其效果而無法解決問題時，則有可能透過「補充性解釋」(ergänzende Auslegung) 的方式探求「假設的當事人意思」(hypothetischer Parteiwille)，以填補該契約約定之漏洞。

筆者要再特別強調者係，理論上雖然法律行為之解釋種類可分成此三大階段，但在實際運作上，當事人就法律行為或契約解釋之爭論，必然多起因於：表意人之真意與相對人之認知「不一致」所致，也就是均必須透過第二階段的「闡釋性解釋」(或者規範性解釋) 始得解決紛爭，因此第二類的「闡釋性解釋」(或者規範性解釋) 實屬居於法律行為解釋之核心。因為如果可以輕易透過「經驗性解釋」而獲得「一致的當事人意思」，即不至於滋生契約紛爭。由此亦可得知，在法律行為解釋上，真正重要者仍屬「闡釋性解釋」，也因而必須連結契約解釋之方法(標準)以求得客觀的當事人可能之意思。至於第三類的「補充性解釋」則究屬例外，而應

87 在下述有關法律行為解釋之標準中，被使用最多的臺灣最高法院判決之論述類型中，具代表性的最高法院102年度台上字第2087號民事判決即正確地表示：「按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八條定有明文。所謂探求當事人之真意，乃在兩造就其意思表示真意有爭執時，應從該意思表示所植基之原因事實、經濟目的、社會通念、交易習慣、一般客觀情事及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果是否符合公平原則。」其意旨即已經隱含地指出：解釋意思表示是在「經驗性解釋」後「仍有爭執時」，始進入對當事人客觀化地「真正被表達的意思」，以其所列出之標準進行「闡釋性解釋」。

88 也有不再區分闡釋性解釋，而直接以「客觀的規範性解釋」(objektiv normative Auslegung) 或「規範性解釋」(normative Auslegung) 代替者，參見Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 18 ff.; Ahrens (Fn. 32), § 133 Rn. 22.

嚴格界定，更難經常認定發生。

為期明瞭，在開始討論以前，先圖示法律解釋之種類如下：

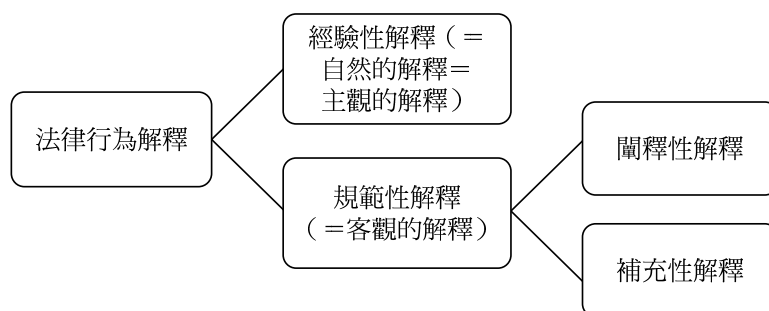


圖3 法律行為解釋之種類

資料來源：作者自製。

(二) 經驗性解釋 (empirische Auslegung)

如前在討論第133條與第157條規定的交錯時所曾敘述的，經驗性解釋考量的是尊重法律行為中自我決定及自我負責原則，因此原則上應該優先適用⁸⁹。依德國民法第133條規定，解釋意思表示應探求當事人真意，此一真意首先不是「客觀的規範上意思」，而是「經驗上的意思」。因為此種經驗上的意思必須被表達出來，故依該條所作的「真（正的）意（思）」(der wirkliche Wille)之探求，並非探求表意人內在之單純意思 (der bloßer Wille)，而是探求表意人所賦予該表示的意義，以及表意人對該意義的「真正的理解」，或者說表意人主觀上、事實上如何理解該已作出之表達（表示），通說因此稱之為「經驗性解釋」（其實相對於闡釋性解釋被稱為客觀規範性解釋，此處也可以對應理解為主觀事實上的解釋）⁹⁰。在須相對

⁸⁹ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 12.

⁹⁰ 此種說法其實也容易理解，因為意思表示如果都是以表意人單純內心的意思為

人受領的意思表示之情形 (empfangsbedürftige Willenserklärungen)，如果相對人對該意思表示之理解與表意人相同，則依其一致性的理解來確定該意思表示的意義⁹¹。也就是說，經驗性解釋對於有爭執部分的解釋，是採取從表意人角度所作的主觀理解⁹²。

經驗性解釋因而著重在：表意人與相對人之間是否已經「一致」理解該意思表示（表意人的真意是否已經被相對人認知），只要雙方當事人已達成一致性的理解，不管是在1. 通常情形下對該文字合乎通常意義之理解，抑或是在2. 表意人疏未使用通常的文字意義，但相對人知悉其意思（即德國法上所謂*falsa demonstratio non nocet*，即「用語錯誤無害真意原則」⁹³），3. 或者在相對人知悉之情形下表面上故意表達該用語（例如心中真意保留為相對人所明知、當事人通謀為虛偽意思表示、他方明知表意人只是善意的戲謔表示等）⁹⁴，則均非所問，該「一致」理解之意思表示的意義，即作為經驗性解釋的結果。此時，重點已經不在於「文字」（Wortlaut），而在於「一致的當事人意思」才是關鍵，因為相對人此時已經認知了表意人的「真意」，並且在此意思認知下訂立契約⁹⁵。

準，那麼就不會有意思表示錯誤而撤銷之問題（德國民法第119條及第120條，相當於臺灣民法第88條及第89條）。第133條僅僅意味著，不是表達出的「文字」本身，而是表達生效後的文字的「意義」才是重要的！

91 Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 1; Eberhard Wieser, Empirische und normative Auslegung, JZ 1985, S. 407 (407); Inge Scherer, Die Auslegung von Willenserklärungen „klaren und eindeutigen“ Wortlauts, Jura 1988, S. 302 (305).

92 Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 11f.; Ahrens (Fn. 32), § 133 Rn. 17.

93 這是羅馬法以來有關意思表示解釋原則的重要法諺（D35. 1. 33 pr.），意指一個錯誤的用語無害意思本身（Eine falsche Erklärung oder Bezeichnung einer Sache schadet nicht）。參見王澤鑑（註3），頁455之翻譯。

94 Wieser (Fn. 91), S. 407.

95 Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 1; Helmut Köhler, BGB Allgemeiner Teil, 39. Aufl., 2015, § 9 Rn. 13: Der Vorrang des übereinstimmenden Gewollten（一致性的意思表示有優先性）。

相對而言，只有在當事人間事實上之理解「不一致」時（因為此時，表意人的真意已經無法被相對人認知），接著才有進一步作規範性解釋（或者客觀的解釋）之必要（此時法律在一定範圍內必須保護相對人對於該被表示意思的信賴），因此德國通說乃一再強調德國民法第133條主要所規定的「經驗性解釋」雖具有優先性⁹⁶，但如果無法達成，則如下述的德國民法第157條針對此而規定的「客觀規範性解釋」則進一步著重考量：相對人在具備交易必要的謹慎下，應該如何理解該意思表示。或者說，依據誠信原則及交易習慣，一般人應該如何理解該意思表示？此時，規範性解釋的對象不再是表意人內心的真意，而是被表達而客觀化的意思。

準此，只要不違反相對人值得保護之利益，經驗性解釋應優先適用（或尊重）自我決定原則。學說上所舉以下兩個案例可供參考。

案例一：某一工廠領班A向雇主U報告，說昨天的整批產品因為機器操作不慎均有瑕疵。A和U因而爭執損失到底有多大以及何人應該對此負責？U最後大喊：「你給我走！」究竟這個意思表示在客觀解釋上應理解為是一種不定期限之終止抑或是結束對話，尚有疑問。但如果雙方當事人均理解為終止契約，則法律上即得如此處理⁹⁷。

案例二：K向V訂購了214桶的Haakjöringsköd，V承諾供貨。雙方當事人一開始就認為Haakjöringsköd就是挪威語的鯨魚肉的意思。然而這個字其實是鯊魚肉的意思。此處如果適用「用語錯誤無害真意原則」，契約當事人所訂立者為鯨魚肉之買賣契約。然而如果就貨物進口之主管機關批准者而

96 Eberhard Wieser, Wille und Verständnis bei der Willenserklärung, AcP 189 (1989), S. 112 (112)及該處註1所引用之通說文獻。

97 Vgl. Bork (Fn. 14), Rn. 520.

言，則為鯨魚肉，因為批准的內容是依據契約的規範性解釋而來的⁹⁸。

(三) 規範性解釋 (nomative Auslegung)

1. 闡釋性解釋 (erläuternde Auslegung)

(1) 解釋標準

如果無法用前述自然的或「經驗性解釋」探求事實上的意思時，即應使用「規範性解釋」。所謂「規範」，指的不是追求表意人事實上想表達的真意，也不是追求表意人事實被理解者，而是借用「評價上的觀察方式」(wertende Betrachtungsweise)(此乃假定意思表示的相對人背後，有一個平均的、信賴對解釋而言之一切重要狀況的、客觀的觀察者存在⁹⁹，從客觀觀察者的角度)來探求：在誠信原則與交易習慣的考量下，相對人可能如何理解該意思表示？亦即透過闡釋意思表示之解釋方法，來尋求「可能的意思」(der mutmaßliche Wille)所在¹⁰⁰。

從客觀觀察者的角度來看，如果表意人一開始作為意思表示的掌控者，且正確而清楚地表達了他的意思，但是他的真意在客觀上卻無法被知悉時，表意人就沒有值得保護之處，「表意人的事實上真意」不再重要。相反地，值得保護的反而是意思表示的相對人，因為他可能信賴了意思表示的通常意義。此時，從法律明確性與法律安定性的角度，乃要求表意人受其可歸責於己所作的意思表示之意義所拘束，而該意思表示的意義，則非來自於「相對人事實上的理解」，而應該是來自於一個「客觀的觀察者所可能賦予的意義，

98 此為德國法上的著名案例，參見RGZ 99, 147 (148); *Albrecht Cordes*, Der Haakjöringsköd-Fall (RGZ 99, 147-149), Jura 1991, S. 352 (352 ff.) 之詳細討論。

99 *Bork* (Fn. 14), Rn. 500, 527.

100 *Bork* (Fn. 14), Rn. 525.

或者說表意人正直而可能預測或理解的意義，或者說相對人在具備必要的謹慎下考慮所有理解可能性與相關具體狀況時所應知悉的意義」¹⁰¹。此種既非取決於表意人的事實上意思，也非相對人事實上的理解，而是從客觀觀察者角度所作的解釋方法，被稱為「客觀化之相對人視域解釋」¹⁰²（Auslegung vom verobjektivierten Empfängerhorizont）¹⁰³。

（2）以「玻璃磚牆案」為例

德國聯邦最高法院曾有過一個案例（一般稱為「玻璃磚牆案」Glasbaustein-Urteil或「窗戶案」Fenster-Fall），常被引用來說明「闡釋性解釋」¹⁰⁴。由於這個案子涉及到包括下述有關參、二、契約解釋的「六準則」中，學說上一再的以此為例說明解釋的方法（包括文字解釋、目的論解釋及利益衡量之解釋等），故在此有先詳細介紹此一案例之事實及理由之必要。

A是一個小印刷行老闆，印刷日報。A的印刷行所在之建築物直接與B的土地相鄰，B則在該土地上蓋有一單人房。為了規範A與B間相鄰關係，二人於1955年5月14日約定：在印刷行建物的建築牆上，也是B之土地所面對的那面牆，不可以安裝窗戶（„Fenster dürfen nicht angebracht werden“）。但A卻在牆上安裝玻璃磚（Glasbausteine），

¹⁰¹ Vgl. auch BGH NJW 2008, 2702 (2704 Rn. 30).

¹⁰² Bork (Fn. 14), Rn. 500, 527.

¹⁰³ 「客觀之相對人視域」（objektiver Empfängerhorizont）的解釋，最早可能來自於Philipp Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, AcP 112 (1914), S. 1 (43). 只是還沒有加上「客觀」二字；參見Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 42. 又Bork強調：從這個角度來看，規範的解釋某程度而言實質上已經不是如何理解表達之文字的問題，也不是文字表達是否有過錯的問題，而是一種風險分配的問題！Bork (Fn. 14), S. 194 Fn. 22.

¹⁰⁴ BGH LM Nr.17 zu § 133 (C) BGB. 「玻璃磚牆案」Glasbaustein-Urteil是1960年7月13日德國聯邦最高法院所做的一個相當有名的判決，後來一再被學者引用說明，參見Bork (Fn. 14), Rn. 527; Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 50; Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 19, 45, 54（在該條註釋中多處一再引用）；Flume (Fn. 16), S. 319.

B乃依約訴請排除。本案爭點在於：依兩造約定之給付義務的內容，是否A只能裝設密閉的牆，而不可以裝設玻璃磚牆？

B認為依兩造契約約定，A有義務不安裝窗戶，這應該也包括有義務不裝設玻璃磚牆。因為契約約定的意義在於：防止夜間也在工作的印刷行建物內的光線，穿透進入B的房間內。

對此，原審高等法院採否定看法，認為不可以安裝窗戶之約定，並不排除裝設玻璃磚牆。理由主要是「依據契約之文義與目的，原告只能在常用的意義下（im landläufigen Sinne）反對開設窗戶，其意涵就在於：可以在界線處不被直接看穿，而且沒有聲響會穿透封閉的窗戶，更不會透過裝設的窗戶而造成干擾，最後也不會有東西被丟擲到相鄰的B的土地上。因此，為了排除這樣的干擾，並不需要排除會透光的牆，相反地，使用玻璃磚牆也可以達到契約目的，如果在地面上設置並與周遭緊密連結，其防止噪音干擾的作用絕不亞於一般的牆，而且標準安裝也是不透明的。因此，契約約定的『窗戶』，依其字義與意義，並不排斥以平面方式使用像玻璃磚牆這種其他的『窗戶性質的裝設』。」

但最高法院認為從「闡釋性解釋」可以得出，契約約定的不可以裝設「窗戶」，應該包括不可裝設「玻璃磚牆」在內，因而指摘高等法院這樣的解釋！

茲先摘錄其判決要旨如下供參：「a. 依據一般的用語，『窗戶』這個概念的關鍵是透光性（Lichtdurchlässigkeit），在本案因此構成窗戶。當吾人以玻璃磚塊裝牆，而不能透過這個牆看穿，也不能讓空氣或聲響穿透時，就滿足了窗戶的性質¹⁰⁵。b. 如果土地相鄰人已經一致約定：從相鄰界線開始，在建築物內不可以安裝窗戶，那麼

¹⁰⁵ 此一要旨主要對應判決細部理由1.及2.，將在下文中略加介紹。（細部理由3.在重印的判決全文中是被省略掉的。）

就禁止法官把一個偏離約定的建築方式，以限縮契約解釋（*einschränkende Vertragsauslegung*）的方式，許可地將其解為是『具有美學價值的』建築。¹⁰⁶」

就判決細部理由1.而言，最高法院認為高院這樣的「字義」解釋「牴觸一般的用語」¹⁰⁷，高等法院把「窗戶」這個概念做了過於狹窄的解釋。根據一般通行的德文用語，吾人理解的「窗戶」字義是指「在建築物中透光」而言（*Lichtöffnungen in Gebäuden*），關鍵在於透光性（*Lichtdurchlässigkeit oder Lichtzuführung*），因而增加的空氣流通之可能性，則較不重要。因為根據經驗，有很多窗戶根本不能開啟，也不能通風，甚至於能否向外看出去，也不是窗戶的概念本質。高院的解釋真正問題在於：沒有賦予其已經提到的「聲響穿透性」（*Geräuschdurchlässigkeit*），在解釋上的關鍵地位。從一般用語來看，應該肯定「牆的穿透性」（*Mauerdurchbrüche*）具有「窗戶的特性」（*Fenster-Eigenschaft*），因此從兩造當時約定的「字義」（*Wortlaut*）「不可以安裝窗戶」，玻璃磚牆的建築方式就已經違反了約定而不應許可。

此外，從契約約定的「意義及目的」（*Sinn und Zweck*），高院認為透過經驗性解釋如果可以確定在訂約時，兩造已經有一致性的意思認為，在相鄰界線的牆上開窗戶，並非絕對禁止，而只有在干擾原告B無礙地使用其土地的範圍內，才是禁止的。對此，高等法院將兩造之前揭約定，解釋為只限縮在他造A不能從相鄰土地看到B，但不包括聲響侵入之干擾（*Geräuschbelästigungen*），因此不包

¹⁰⁶ 此一要旨對應在判決細部理由4.及5.。

¹⁰⁷ 為了確認這個用語的定義，最高法院查考引用了包括：*Sprach-Brockhaus*, 6. Aufl., S. 192; *Perkum*, *Das deutsche Wort*, 1953, S. 276; *Grimm*, *Deutsches Wörterbuch*, 3. Bd. Sp. 1519; *Großer Brockhaus*, 16. Aufl., Bd. IV, S. 23; *Meisner/Stern-Hodes*, *Nachbarrecht im Bundesgebiet*, 3. Aufl., § 25 A等。因此這個案例也被引為下述契約解釋六準則中，透過「一般的用語」確認的契約文字的「字義」之典型範例。

括禁止使用玻璃磚牆。對於高院此種見解，最高法院在細部理由2. 認為高院所做之「限縮解釋」是不正確的、偏離字義的契約解釋。亦即，最高法院認為高院這樣的解釋違反解釋之原則，且建立在錯誤或者說不完全的利益衡量上，因為從約定的字義來看，契約的字義是完全禁止任何裝設窗戶的行為的，但是，高等法院卻限縮解釋成為有利被告的「只限於某些干擾原告的裝設窗戶行為」。

又，高等法院以附帶說理（Hilfsbegründung）方式認為：被告選擇以玻璃磚牆的方式興建建築的牆面，是個人品味的選擇，具有美學價值的建築方式，一開始兩造所預見的「不能安裝窗戶」應該是建立在傳統粗糙的牆面意義上，當時應該未曾想過（因此也不包括）此種在科技上具有同樣價值的（gleichwertig）建築方式。對此，最高法院在細部理由4. 加以指摘，認為高院是「以自己的美感，取代當事人的美感，超越了法官權限行使的界限」。因為美學品味人人不同，當事人既然在契約自由下形成自己的法律關係，要求封閉的牆面，「法官就無權以限縮契約解釋的方式，以另一個當事人不要的答案，以其是與契約約定在美學上是等價者為理由，強迫當事人接受」。價值同樣與否，其標準過於主觀。

更重要的，也是前揭判決要旨未摘錄者，是在最高法院細部理由5. 認為，從利益衡量的角度來看，如果按照高等法院的此種解釋，鄰地被告可以以玻璃磚牆開窗安裝時，鄰地所有人將來有一天要在自己土地上建築房屋，其建築權將會因為德國建築法的規定而受到限制（不能建築到雙方的土地界線上¹⁰⁸），「因為這將會妨礙鄰居的光線權（Lichtrecht），因而減損原告B的土地價值，該土地將來勢必無法出售或售價較低」，影響原告的主要利益¹⁰⁹，這點是高

108 依該判決所載當時相關的建築法規，如果被告A之建築物開窗超過十年，原告B的土地將來就不能建築到達邊界線上，土地上的新建物必須大幅退縮到鄰地建物的地面層可以看到天空。

109 並參見Flume (Fn. 16), S. 319特別強調此點。

等法院作出上開解釋時未曾利益衡量者。而這個利益應該是契約雙方訂立該約定背後，重要的利益考量，也是因此最高法院採取否定被告A可以開設玻璃窗戶的原因¹¹⁰。

2. 補充性解釋（ergänzende Auslegung）

（1）解釋步驟與思考流程

一旦經驗性解釋與闡釋性解釋都無法形成當事人需要的法律效果，也就是當事人之法律行為對此未作任何表示。此時，法律行為不圓滿，與法律規定不圓滿類似，因此某程度也准許類推適用¹¹¹。如果是當事人已經知悉問題，但故意不為約定，則為有意的契約漏洞（bewusste Lücke）；如果是當事人因未曾預見該問題而未約定，則為無意的自始漏洞（unbewusste anfängliche Lücke）或者當事人根本不可能預見，因為是事後才發生約定之需要，則為無意的嗣後漏洞（unbewusste nachträgliche Lücke）¹¹²。此時則有採取「補充性解釋」¹¹³之必要，也就是契約漏洞之填補。

110 並參見Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 54.

111 Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 58（「當事人契約的規定計畫容許也要求原則上可以類推適用」），例如當事人租賃契約約定不可以養狗，此時應該類推適用到也不可以養猩猩（Wolf/Neuner (Fn. 49), Rn. 24）。

112 BGH NJW-RR 2008, 560 (562 Rn. 14); NJW 2002, 1260 (1262).

113 值得附帶介紹的是，Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 66 ff. 對於通說及實務使用「補充性解釋」這個概念所採取的批判性看法。氏將契約類比於法律，採取類似Larenz法學方法論之法官造法的三階層構造論（即：法律解釋、法律補充、法律創造），亦即契約解釋（Auslegung），契約補充（Ergänzung）與契約修正（Korrektur）三部曲，因此對於確定契約規定有違反當事人計畫的不圓滿性時，應該允許「填補（補充）」契約漏洞。但是實務及通說卻使用所謂的「補充性解釋」這個概念。Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 68認為這個概念在方法論上是矛盾的，因為當我們把意思表示類比如同法律一樣時，不是解釋就是補充。解釋與補充二者的界線雖然是流動而複雜，但是契約解釋者的任務就在於區分：重建私法自治所形成的當事人意思（解釋）與由他人透過諸多要素確定假設的當事人意思（補充），二者的不同。但最高法院卻在補充性解釋背後隱藏了法官造法的決定。使得補充性解釋這個「獨立的法律制度在功能上變成一個法源的重大不透明」。

德國聯邦最高法院認為補充性解釋的法律基礎在於德國民法第133條及第157條¹¹⁴，學說文獻上則有人主要引用第157條及第242條（誠信原則）¹¹⁵，補充性解釋的目的，如前所述地則在探求「假設的當事人意思」。

學說上一般認為，此種解釋之進行有三個步驟¹¹⁶：

1. 第一步驟是「漏洞確認」（Lückenfeststellung）：應先確認是否有規定漏洞（Reglungslücke）之存在。

「只要依據當事人規定計畫範圍內，法律行為有未規定之處」，即屬有契約漏洞¹¹⁷，在契約規定中應規定之點未規定而有契約之規定漏洞，構成補充性解釋之前提要件¹¹⁸。至於當事人就某一有疑問之點究竟是否已經有規定或者未曾規定，則必須先透過前述經驗性解釋與闡釋性解釋，進行探究釐清¹¹⁹。一般來說，如果在契約所涵蓋的範圍內或者事實上當事人想要約定的範圍內須要加以補充者，就是存在有契約漏洞。特別是如果當事人想要達成特定的目的，但是依照現有契約約定無法達成者，就有「違反規定計畫的漏洞」¹²⁰。但應先說明者係，此時契約約定的字義，就不再是確認契約漏洞的適當標準，因為有可能有當事人默示的表示，而且當事人的意思應該有優先性¹²¹。

114 BGH NJW 2015, 955 (957, Rn. 26).

115 Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 66.

116 簡要說明參見Bork (Fn. 14), Rn. 533.

117 BGHZ 158, 201 (206); BGH NJW 2015, 955 (957 Rn. 27); 2013, 678 (679 Rn. 15); NJW-RR 2005, 205 (206); 2000, 894 (895); NJW 2002, 1260 (1262); 1998, 1219 (1219); 1994, 1008 (1011); Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 57; Ahrens (Fn. 32), § 133 Rn. 25特別強調：可以透過補充性解釋填補表意者的意思表示，可能是要式的法律行為，可能是遺囑，也可能是多數共同體意思。

118 Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 15及該處詳細引用之文獻。

119 Flume (Fn. 16), S. 323.

120 Wolf (Fn. 82), § 157 Rn. 123.

121 Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 58.

2. 第二步驟則是審查有無「任意規定」(dispositives Recht)：如有任意規定，有無必要以補充性解釋填補漏洞 (ob die Lückenfüllung nötig ist)？

也就是雖然有未規定之處，但如果該漏洞透過任意規定就可以加以填補，則不再須要補充性解釋，這也是學說上所強調的任意規定的「秩序功能」(Ordnungsfunktion)¹²²。也就是說，任意規定應始終先於補充性解釋，這是因為立法者以典型的法律任意規定作為基礎而分配的當事人利益狀態，也應該適用於系爭具體待決之爭議案件¹²³。最典型的例子就是買賣瑕疵擔保之規定，如果當事人給付有瑕疵之物，買受人要求出賣人負擔保責任，此時只要援引民法上規範此種典型利益狀態有關於瑕疵擔保的任意規定即可，不必再透過補充性契約解釋¹²⁴。又例如一般契約中不會特別約定，有關債權人或債務人給付遲延或給付不能等義務違反，而當事人死亡時如何繼承之情形，也可以透過此等任意規定加以處理。「任意规定的功能就在於減輕當事人對相關事務的顧慮。¹²⁵」此外，如下所述地，補充性解釋在結論上有著高度的不確定性與法官恣意性，因此有先以任意規定加以嚴格限定必要。

如果不是此種情形，才有考慮以補充性解釋，處理該非典型的利益狀態。亦即以補充的解釋，創設一個「補充契約的契約規定」(eine vertragliche vertragsergänzende Regelung)，而以該規定排除法律的任意規定。

¹²² Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 60則強調如果確認契約有漏洞，契約當事人應該先有義務透過「事後協商」(Nachverhandlung)式，填補該漏洞。無法協商時，才進到任意規定的參考體系內。

¹²³ BGHZ 177, 186 (191 Rn. 18); 176, 244 (255 Rn. 32); Köhler (Fn. 95), § 9 Rn. 17 ff.; Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 23則強調這是通說及最高法院判決的穩定見解。

¹²⁴ Bork (Fn. 14), Rn. 535.

¹²⁵ Medicus (Fn. 18), Rn. 344.

3. 第三步驟則是進行「漏洞填補」(Lückenfüllung oder Lückenschließung)：如果因為沒有足夠的任意規定可資適用，此時就要進到第三步驟審查：是否可能填補漏洞(ob die Lückenfüllung möglich ist)？

因為每個法律行為都含有當事人特定的基本決定與評價，在進行補充性解釋時，應該要延續當事人的這些決定與價值。問題在於：何以填補當事人現存計畫不足的補充答案，是符合當事人利益，而在爭執點上為雙方當事人所能接受？此一程序也被稱為是尋找「假設的當事人意思」¹²⁶，也就是說：如果當事人當時有想到這個爭執點，雙方應該可能會如何約定？

Medicus強調，補充性解釋至少有三個不同層面的論證：假設的當事人意思、慣行性(Üblichkeit)以及衡平性(Billigkeit)。

在第一個層面的論證上，Medicus提出警告：「尋找『假設的當事人意思』之過程，經常是不可靠的，因為如果當事人已經發生爭執了，通常他們會對一方就該爭執點主張的意思，提出反對的主張。德國聯邦最高法院在其判決中就曾經表示：假設的當事人意思『與私法自治沒有直接的連接點』，因為它不是訂約當事人主觀的想法所決定，而是基於法院在客觀基礎上的利益衡量所作成。¹²⁷」並且正確地將「假設的當事人意思」予以具體化為：「『所謂假設的當事人意思』關鍵在於：正直而理性的當事人在認知到違反計畫的規定漏洞時，依契約目的以及雙方當事人合乎事理的利益衡量，本於誠信原則，將會作如何之約定。¹²⁸」

126 Bork (Fn. 14), Rn. 537; Medicus (Fn. 18), Rn. 342也強調：「吾人可把補充性解釋之標準稱為假設的當事人意思。」

127 BGHZ 96, 313 (320 f.).

128 BGHZ, NJW 2010, 1742 (1742 Rn. 18); 2006, 54 (55 Rn. 25); Wolf (Fn. 82), § 157 Rn. 118特別強調：此限於債權行為，物權行為(契約)因為必須作土地登記公示，因此無以補充性解釋探求假設的當事人意思之餘地。

此外，補充性解釋還有另外兩個因素要討論，也就是德國民法第157條提示的必要考量的交易習慣及誠信原則。其一是「交易習慣」（或商業慣例）就是考量「慣行性」的意思，例如某一個旅行社在一個大飯店訂了一個房間，後來因故旅行團無法成行，是否在慣例上距離約定日期如果還有相當的時間，就沒有損害賠償責任。其二是「誠信原則」則是發揮「衡平性」的意思，這取決於當事人的「正直行為」與否，在上開旅行社的例子如果不能解除訂房，應該考量的是：是否造成旅行社無可預期的風險？飯店能否自己處理該解除訂房的空位？

學說上認為，補充性解釋有幾點應該特別注意者。首先要特別謹慎的是，即使透過上開「假設的當事人意思」、「慣行性」與「衡平性」論證，結論也幾乎無法預見，因而具有高度的「法律不安定性」。「法官取代了當事人成為法律關係的主人。法官最終決定，當事人應該如何形成其交易。法官特別在援引誠信原則或當事人正直行為的概念下，命令與真正的或假設的當事人意思沒有任何關聯的交易內容。把私法自治變成法官式填鴨（*richterliche Gängelung*）。¹²⁹」其次，補充性解釋絕對有可能得出如下結論：因為找不到符合雙方利益且為雙方可接受的之答案，所以無法填補該漏洞¹³⁰！最後是，補充性解釋只能在雙方約定的契約框架內填補漏洞，不得變更契約之客體或者修正當事人可得確定之意思¹³¹。把當事人既有的契約約定修改得更好或更符合雙方意願，絕非補充性解釋之任務¹³²。

因此，補充性解釋須要嚴格加以界定。此何以前述地，應該優先以任意規定來補充不圓滿的當事人約定，如果任意規定不能適用，也應該透過法律解釋的方法（特別是目的論解釋）進行說理，

129 詳見*Medicus* (Fn. 18), Rn. 344的精彩論述。

130 BGH NJW-RR 2005, 1040 (1040); 2005, 458 (460).

131 *Wolf* (Fn. 82), § 157 Rn. 126.

132 BGH NJW 1988, 1479 (1480).

何以該具體交易因為特殊性而無法適用該任意規定，以避免補充性解釋的不確定性與防止法官的恣意性。

茲圖示法律行為解釋之思考流程如下：

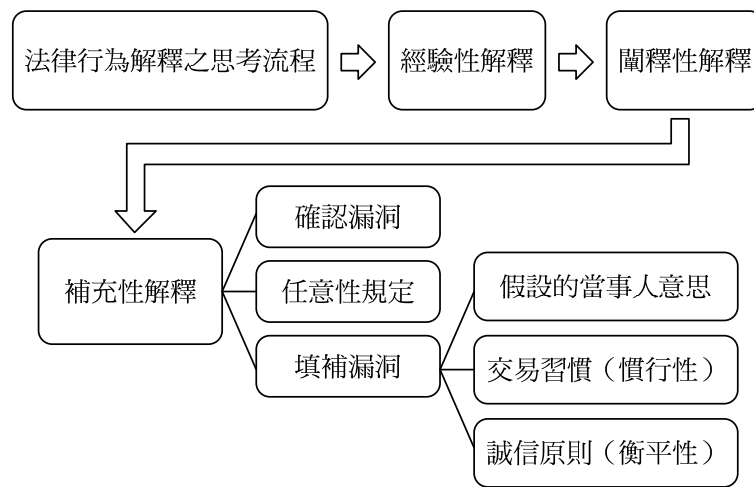


圖4 法律行為解釋之思考流程

資料來源：作者自製。

（2）臺灣判決運用情形

看完德國學說介紹後，接著應該對應說明者，係臺灣對於法律行為或契約解釋中，有關於闡釋性解釋或補充性解釋運用之情形。

A. 分析「巴里島社區案」之見解

就本文一開始的「巴里島社區案」而言，應先說明者係本案與本文之主題有三點相關特色：

a. 區分「闡釋性解釋」與「補充性解釋」

在「巴里島社區案」中，法院判決謂「意思表示不明確，使之明確，屬意思表示之解釋；意思表示不完備，使之完備，屬意思表示之補充。」在思維上已經明白地區分經驗性解釋或「闡釋性解釋」，以及填補法律行為或契約漏洞的「補充性解釋」二個不同層次了，只是未使用類似概念而已。只不過最高法院除了下述使用的解釋標準中，又列出「任意法規」，但此要素主要是作為填補契約之先前要素，而屬於「補充性解釋」者，已如前述，就此而言，最高法院又略有混淆之嫌。

b. 使用解釋之標準

接著法院判決列出不同的解釋標準，且使用「恆須加以闡釋」，可見該判決是在進行第二層次的「闡釋性解釋」。如果對應下文中所列出的「六準則」來進行對應思考，此時法院除了提及「文義」之標準外（判決文字謂「在解釋有對話人之意思表示時，……表意人所為表示行為之言語、文字或舉動，……應以交易上應有之意義而為解釋」，可見法院是以「交易上一般之意義」來理解文義解釋），又提及「法律行為之解釋方法，應以當事人所欲達到之目的、習慣、任意法規及誠信原則為標準，合理解釋之，其中應將目的列為最先，習慣次之，任意法規又次之，誠信原則始終介於其間以修正或補足之」，亦即又列出契約目的（或經濟目的）、交易習慣、誠信原則等標準。此外，判決另提到的「法律行為之和諧性」所指為何，不甚清楚，筆者在德文文獻中似未找到類似概念，但就內涵來看，最高法院或許是強調解釋應注意使法律行為規定，在體系上前後無矛盾，若果如此，則似應指本文所列「六準則」之體系解釋而言。準此，則本文所列「六準則」思考，最高法院除了歷史解釋外，已注意到其他五種解釋標準（即文義解釋、體系解釋、目的論解釋、交易習慣、誠信原則），令人讚佩。

c. 解釋標準以目的為優位？

值得注意者係，最高法院特別強調此等解釋標準之優位順序為：「應將目的列為最先，習慣次之，任意法規又次之」。然而，何以交易習慣優先於任意法規，筆者亦感疑惑，但最高法院將「目的論解釋」列為最優位，且本件判決結論也採取「乙應提供D土地與ABC土地合併計算總面積後，分配與各該ABC（土地上）三棟有關房屋之客戶，不得有何減損甲取得基地應有部分之行為，方符契約當事人之目的解釋」，否則即屬「誤解契約之文義」，明顯採取目的論解釋優位於契約文義的立場，則最高法院似乎在解釋標準順序上明白採取「目的論絕對優位」或至少「初步優位」，而與德國以及我國學者通說不同¹³³，在法學方法論上之見解是否有轉變，值得注意。

B. 從嚴認定契約漏洞與補充性解釋

關於契約是否與法律相同，均有漏洞存在而有填補之必要，最高法院95年度台上字第2309號民事判決謂：「次按，類推適用，係就法律未規定之事項，比附援引與其性質相類似之規定，加以適用，為基於平等原則及社會通念以填補法律漏洞的方法，倘無法律漏洞，自不生類推適用而補充之問題。基於同一法理，於契約條款之類推適用，亦須於契約未約定之事項，始有比附援引其他條款適

¹³³ 關於法律解釋（在本文，契約解釋亦同）的標準或要素，例如文義或目的解釋結果不同時，是否有一個固定的優位順序，德國通說以及我國學者通說向來採取否定見解，亦即目的解釋並不優位於文義解釋或其他解釋標準。但最近學說上有採取德國其他學者見解，認為目的解釋具有「初步優位」，亦即此一解釋標準具有初步第一眼即判定的優先順序，除非有特別強的反對論證，則可以推翻該優位順序，但想要偏離該初步優位順序的解釋者，則對此負有論證及說理義務。學說上據以驗證國內最高法院見解者，參見吳從周，台灣民法方法論之發展現況——特別聚焦法律解釋方法在法院實務之運用狀況，收於：戴東雄教授八秩華誕祝壽論文集委員會編，身分法之回顧與前瞻——戴東雄教授八秩華誕祝壽論文集，頁523以下（2017年）。

用之餘地。系爭工程契約已將工程延期之原因及效果約定，自非屬契約未約定之事項，自無類推適用『公路局投標須知』第十四條規定之餘地。原審因以上述理由，為不利於上訴人之論斷，經核於法洵無違誤。」似乎就是肯定「契約漏洞」的存在與填補之問題，而間接肯認有「補充性解釋」適用之餘地。

此外，以下兩個判決也進一步肯定闡釋性解釋以及契約漏洞作為例外進入適用「補充性解釋」之前提，因為法院在結論上多從嚴否定補充性解釋之可能。就此而言，法院判決結論值得肯定。

對此，最高法院105年度台上字第1902號民事判決即謂：「按解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準。就契約進行補充性之解釋，非確認當事人於訂約時，關於某事項依契約計畫顯然應有所訂定而漏未訂定，致無法完滿達成契約目的而出現契約漏洞者不得為之，俾尊重當事人自主決定契約內容之權利，並免於任意侵入當事人私法自治之領域及創造當事人原有意思以外之條款。……原審……未究明系爭契約是否確有漏洞，即逕依誠實信用原則及對系爭契約為文義外之補充解釋，……自嫌速斷。」

接著，最高法院106年度台上字第962號民事判決也謂：「按當事人於訂立契約時，關於某事項依契約計畫顯然應有所訂定而漏未訂定，致無法完滿達成契約目的而出現契約漏洞者，法院始應為補充性之解釋（契約漏洞之填補），倘當事人對於契約所生之法律關係，已加以約定，或對於契約之解釋及適用並無障礙或困難時，基於私法自治及契約自由之原則，並無就契約之法律性質，加以定性並為補充性解釋之必要，而應逕依契約之約定決定其權利義務關係。」

C. 「直升機維修案」

最近，最高法院針對個案再度表示「闡釋性解釋」（判決內文用「闡明性解釋」）與「補充性解釋」適用之區別與界限者，是在最高法院103年度台上字第713號民事判決。因其宣示之見解極具有代表性意義，有略加介紹必要。

本件高院認定之基本事實為：兩造間有關飛機維修之系爭契約招標規範相關規定（特別是有關扣款的規定）如下：伍、一、飛機預防保養及檢修商維案內容及規範，被上訴人係承攬上訴人所有之UH-1H、B-234直升機之飛機預防保養及檢修工作。伍、一、（十七）「隨機裝備定期保養檢查及維修（工時、料件、耗材、行政費用等均包括在本商維案範圍內）」之1.（1）規定，HU-1H救生吊掛之定期保養檢查及維修應依技術手冊執行。伍、一、（十一）特別檢查之3規定，上訴人依實際需要，得要求被上訴人執行全機或部分特別檢查。陸、七責任排除之（三）、（六）規定反對解釋，如係因可歸責於被上訴人之事由所造成之增加工作期程，被上訴人不得主張責任排除，亦即仍應認為不妥善。陸、附則：七、責任排除：（三）非維修不當、非正常操作所造成之損壞、意外。（六）因上述原因或其他非可歸責於承商之事由所造成之增加工作期程，該部分不計妥善。陸、十一「減價方式」（二）2. 規定救生吊掛：隨機妥善數每不足一套每日扣減5,000元。

嗣因UH-1H型、NA-511號直升機（下稱系爭直升機）發生救生吊掛機具（下稱事故機具）失效而肇致人員墜地受傷事故（下稱系爭事故），被上訴人乃通知伊停用UH-1H型直升機所使用之其他同型救生吊掛機具（下稱系爭機具）全部，並進行特別檢查。

兩造爭執在於：此種因為個案失事而停用之特別檢查，能否構成扣款理由？

高等法院認為被上訴人之扣款有理由。理由為：「依系爭規範伍、一、(十七)『隨機裝備定期保養檢查及維修』之1(1)規定，UH-1H救生吊掛之定期保養檢查及維修應依技術手冊執行。又上開伍、一、(十一)特別檢查之3規定，被上訴人依實際需要，得要求上訴人執行全機或部分特別檢查。另依上開陸、七責任排除之(三)、(六)規定反面解釋，如係因可歸責於上訴人之事由所造成之增加工作期程，上訴人不得主張責任排除。所謂『實際需要』應包括可歸責於上訴人之事由致生危害人身安全之飛航安全之特別檢查。是因可歸責於上訴人之事由，致停用特別檢查時，自應列為未妥善，始符系爭契約之目的及真意。」

但最高法院首先宣示下列重要見解：「按契約乃當事人間在對等性之基礎下本其自主之意思、自我決定及自我拘束所成立之法律行為，基於私法自治及契約自由之原則，契約不僅在當事人之紛爭事實上作為當事人之行為規範，在訴訟中亦成為法院之裁判規範。因此，倘當事人所訂立之契約真意發生疑義時，法院固應為闡明性之解釋，即通觀契約全文，並斟酌立約當時之情形及其他一切證據資料，就文義上及理論上詳為推求，以探求當事人締約時之真意，俾作為判斷當事人間權利義務之依據。惟法院進行此項闡明性之解釋（單純性之解釋），除依文義解釋（以契約文義為基準）、體系解釋（綜觀契約全文）、歷史解釋（斟酌訂約時之事實及資料）、目的解釋（考量契約之目的及經濟價值）並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷外，並應兼顧其解釋之結果不能逸出契約中最大可能之文義。除非確認當事人於訂約時，關於某事項依契約計畫顯然應有所訂定而漏未訂定，致無法完滿達成契約目的而出現契約漏洞者，方可進行補充性之解釋（契約漏洞之填補），以示尊重當事人自主決定契約內容之權利，並避免任意侵入當事人私法自治之領域，創造當事人原有意思以外之條款，俾維持法官之中立性。又解釋契約須以邏輯推理及演繹分析之方法，必契約之約定與應證事實

間有必然之關聯，始屬該當，否則即屬違背論理法則。且契約如有疑義時，應盡量避免作成偏向不利於債務人之解釋，以防對經濟弱者之權益造成損害（法國民法第一千一百六十二條參照，該規定乃事物本質之本然及應然，自可當成法理）。」

接著對應本件事實，最高法院認為：被上訴人對上訴人扣款之依據為系爭約定「救生吊掛：隨機妥善數每不足一套每日扣減五千元」，亦即上訴人如未依系爭契約及技術手冊執行預防保養及檢修，提供足額妥善救生吊掛機具時，被上訴人得每套扣減五千元。但本件則是因系爭直升機因事故機具失效而肇致人員墜地受傷事故，此單一事件應僅係被上訴人對上訴人能否請求賠償損害之問題，與系爭約定得為扣款之情形無涉。否則就是在進行「逸出契約中最大可能文義」之補充性解釋。

因此得出結論認為：「原審未遑究明系爭契約是否確有漏洞？即逕對之作補充性之解釋（超出契約最大可能之文義），進而為上訴人不利之論斷，依上說明，尤嫌速斷。」而將原判決廢棄發回¹³⁴。

134 本件廢棄發回後，更一審判決（臺灣高等法院103年度上更(一)字第49號民事判決）完全採取最高法院之見解，否定系爭契約可以進行「補充性解釋」，而駁回當事人之請求。其判決理由如下：「……系爭直升機保養契約既未就直升機或隨機裝備於經上訴人依法或依命令停飛或停用期間，以及因實施特別檢查而停飛或停用期間，該等直升機、隨機裝備之事實狀態是否『妥善』、得否據以減價為免於調查、證明之特約，而系爭直升機保養契約為兩造在對等性之基礎下本其自主之意思、自我決定及自我拘束所成立之法律行為，基於私法自治及契約自由之原則，契約不僅在當事人之紛爭事實上作為當事人之行為規範，在訴訟中亦成為法院之裁判規範，因此，倘當事人所訂立之契約真意發生疑義時，法院固應為闡明性之解釋，即通觀契約全文，並斟酌立約當時之情形及其他一切證據資料，就文義上及理論上詳為推求，以探求當事人締約時之真意，俾作為判斷當事人間權利義務之依據，惟法院進行此項闡明性之解釋，除依文義解釋、體系解釋、歷史解釋、目的解釋並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷外，並應兼顧其解釋之結果不能逸出契約中最大可能之文義，除非確認當事人於訂約時，關於某事項依契約計畫顯然應有所訂定而漏未訂定，致無法完滿達成契約目的而出現契約漏洞者，方可進行補充性之解釋，以示尊重當事人自主決定契約內容之權利，並避免任意侵入當事人私法自治之領域，創造當事人原有意思以外之條款。系爭直升機保養契

關於本件判決延續前述最高法院數則判決中已表示之見解，應再說明者為：

第一、最高法院第一次在區分「闡釋性解釋」與「補充性解釋」之思維下，使用此二個用語。並且強調「進行此項闡明性之解釋（單純性之解釋），除依文義解釋（以契約文義為基準）、體系解釋（綜觀契約全文）、歷史解釋（斟酌訂約時之事實及資料）、目的解釋（考量契約之目的及經濟價值）並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷」，明白採取與法律解釋之標準相同，並兼顧法律行為解釋而與本文相同之「六準則說」，非常令人佩服。

第二、最高法院不再採取前述解釋標準初步優位說，而採取綜合判斷之整體評價法，與目前學者通說見解相同，但顯然與前揭「巴里島社區案」不同，此點恐有待最高法院統一見解。

第三、有疑問者，係本判決強調「闡釋性解釋」之結果不能逸出「契約中最大可能之文義」，雖然有學者如此強調，但似與下述法律行為解釋之通說不同，誠如下文中即將引述者，德國通說及實

約全文為陸點，其中第伍點有二條文，第一條『飛機預防保養及檢修商維案內容及規範』有二十三項，詳載每日預防保養及檢修、階段或定期檢查、狀況評估、組件更換、特別檢查、維修、備份料材取得及檢測、執行飛安通報及航空安全通報或適航指令及安全服務通報、隨機裝備定期保養檢查及維修、技術支援服務、飛機構型管理、飛安事故預防處理及調查、母基地管理中心暨維修小組設置、子基地維修人員設置等諸多工作項目之具體內容、計算方式、時數、執行方法、頻率、標準及費用之負擔等，第陸點下亦有共二十五條，詳細約定進駐、場地、人員管理、支援、試車試飛及油料、進出廠管制、責任排除、督導查核、驗收、付款、減價、損害賠償、飛行超時、技術文件等……，甚為詳盡、具體、明確，並非簡陋殘缺，尚無由法院於契約文義、條款之外，逕就停飛停用期間之『妥善』狀態舉證責任分配或不利益負擔為補充解釋之餘地。至U型直升機上序號三八八號救生吊掛機具於一〇〇年五月二十一日失效導致人員墜地受傷事故，乃上訴人得就此單一事故對被上訴人扣款及請求損害賠償問題，與上訴人得否就其他非事故之救生吊掛機具依首揭約定扣款情形無關，則上訴人自仍應就如附表所示數量之救生吊掛機具於是段期間是否『不妥善』此一事實狀態舉證，無由僅以該等救生吊掛機具遭停用為由，指為『不妥善』，進而予以減價。」

務上特別強調，「不論對於法律行為的闡釋性解釋或補充性解釋而言，一個意思表示是否使用清楚的字義，均不構成解釋的界限」，因為「德國民法第133條正是規定法律行為之解釋，不得拘泥於文字，更何況就是因為法律行為使用的文字字義不夠清楚，才必須要作解釋」¹³⁵。

第四、又法國民法典第1162條規定：「契約有疑義時，應做不利於債權人而作有利於債務人之解釋」，此一條文基本上也是將下述法律行為解釋標準中目的論解釋，德國通說及實務普遍的承認所謂對於免責條款有疑問時從嚴解為作不利於條款擬定人的限制解釋原則（Restriktionsgrundsatz），亦即所謂「不清楚應歸主張有特別權利者負擔不利益」之限制解釋原則。本判決法官罕見地透過民法第1條法理，引為目的論解釋之內容作補充，法律思維相當深厚而廣泛，判決結論值得讚佩。

參、法律行為解釋與法律解釋

一、法律行為解釋與法律解釋之異同

羅馬法上早有「契約即當事人間之法律（contractus est lex inter partes）」¹³⁶之思想，但關於法律行為之解釋（或者說契約之解釋）與法律之解釋二者有何不同，文獻上則尚有不同之說法。學說上有強調解釋法律重在法規文義的客觀性與安定性，注重法規文字的客觀文義，以求達成一般確實性；解釋法律行為則重在探求當事人真

¹³⁵ 請特別參見Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 27及該處註109所引用的學者文獻。Soergel註釋書特別以「字義不是解釋的界限」（„Wortlaut keine Grenzen der Auslegung“）作為標題，澄清此一疑問，值得注意。並參見下述註147、148。

¹³⁶ 感謝審查委員提醒筆者此一羅馬法以來之觀念，藉以提示法律行為解釋與法律解釋之異同。

意，注重意思表示之目的性及行為的具體妥當性¹³⁷。有論者提醒，法律適用於每一個人，法律行為通常指針對於特定人（特別是意思表示的相對人），故對於意思表示的理解應該先取決於表意人的意思，接著從相對人的視域來作解釋，但法律的解釋則要求較強烈的客觀性，其前後脈絡不是一個法律關係的糾結，而是一個法律秩序¹³⁸。亦有指出，為適用法律以定法律行為之法律效力，一方面應明確應適用的法律之意義，以定邏輯上之大前提，他方面須明確應受適用之法律行為之意義，以定邏輯上之小前提。前者為法律解釋之問題，後者為法律行為解釋之問題¹³⁹。

只不過，重點應在於：在解釋的標準（方法）上，19世紀時就已經普遍地把法律解釋的方法，移用到法律行為的解釋，19世紀以後法院甚至就普遍援用德國民法第133條及157條作為依據。到今日通說已經普遍承認，除了應注意二者在解釋對象上的不同特性外，法律解釋方法與法律行為的解釋方法二者是可以平行地相互援用¹⁴⁰。

這主要是來自於1840年von Savigny在他的「當代羅馬法體系」（System des heutigen römischen Rechts）第一冊中提出的法律解釋學之新內容所引起的「法學方法論的大躍進」¹⁴¹（Quantensprung in der Methodentheorie），當時他就已經把法律解釋的想法聯結到法律行為的解釋了。在von Savigny所提出的著名的「四準則」（Viererkanon），亦即「文法解釋」、「體系解釋」、「歷史解釋」、「邏輯解釋」¹⁴²作為解釋的標準之後，法律解釋的標準在德國一直到今

137 施啟揚，民法總則，頁286（2007年）。

138 Busche (Fn. 20), § 133 Rn. 46.

139 史尚寬（註1），頁413。

140 Busche (Fn. 20), § 133 Rn. 6; Flume (Fn. 16), S. 309; Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 33及S. 583 Fn. 115所引用之文獻。

141 這是借用Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 10中的描述。

142 「邏輯解釋」在19世紀後期因為Rudolf v. Jhering對法律目的的思想倡導而被「目的論解釋」所取代。

日仍被引用為法律行為解釋的標準¹⁴³。應特別強調者係，這裡的「法律行為之解釋」，連結前述第133條及第157條之解釋分工，此當然是指無法以「經驗性解釋」取得一致性的意思表示確認，而進入規範性解釋，但尚未進到契約漏洞補充（「補充性解釋」）之前的之「闡釋性解釋」而言¹⁴⁴。

二、法律行為解釋之「六準則」

德國立法者雖然僅列出四種法律行為或契約解釋的標準（第133條的「文字」、「真意」；第157條的「誠信原則」、「交易習慣」），而未列出解釋的方法，但立法者完全沒有要限制在這幾個標準上，相反地，這幾個標準只是具有「指示」作用，立法者要求在探求意思表示時，包括：交易慣例，當時的語言習慣或意思表示的位置或者說表意人的居住地，先前磋商的過程，綜合其他的約定，法律行為的顯見目等等，一切狀況也都應該一起考量，已如前述¹⁴⁵。而法院實務在歐洲百年來解釋學發展的基礎上，也已經形成接近經驗法則而有拘束力的解釋原則¹⁴⁶。不過，即使解釋的考量的要素可能甚多，但綜合歸納文獻上臚列的標準，主要還是以對應法律解釋的四個標準（前述的「四準則」）加以涵蓋，再加上法律行為解釋所特有的交易習慣與誠信原則兩個標準，或許可稱為「六準則說」。本文認為以「六準則說」涵蓋可能考慮的法律行為解釋之要素，較為簡明扼要，也有助於反思與提綱挈領地釐清下述臺灣實務判決中紛亂的諸多要素。

¹⁴³ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 10, 44.

¹⁴⁴ 不過也有學者，在此處直接以規範性解釋代替闡釋性解釋者。例如Flume (Fn. 16), S. 307-321.

¹⁴⁵ 同註28對德國民法立法理由之引述。

¹⁴⁶ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 45; Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 44.

1. 文字解釋（文義，Wortlaut）

從德國民法第133條可以看出：文字是解釋的起點，但不是唯一標準¹⁴⁷。很有可能法律行為偏離其表達的文字，而賦予其比公正的觀察方式所理解的意義，完全不同於字義的另一種意義。應特別強調者係，關於文字的字義是否作為法律行為解釋的界限，德國學者通說及實務特別強調，「不論對於法律行為的闡釋性解釋或補充性解釋而言，一個意思表示是否使用清楚的字義，均不構成解釋的界限」，因為「德國民法第133條正是規定法律行為之解釋，不得拘泥於文字，更何況就是因為法律行為使用的文字字義不夠清楚，才必須要作解釋」¹⁴⁸。「即使意思表示的字義清楚而明確，也不妨礙根據整體情況作補充性解釋」¹⁴⁹。

在此，一般的用語與特別的專業用語，有區分必要，特別例如非法律人使用法律的專業用語時，也常發生專業用語跟其事實上的意思不同¹⁵⁰。即使如前所曾引述的德國民法第133條之前身德國一

¹⁴⁷ 這是德國通說及實務的見解，參見Busche (Fn. 20), § 133 Rn. 59; Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 5; BGHZ 124, 39 (44 ff.); BGH NJW 2010, 64 (65 Rn. 18); BGH NJW 2010, 2422 (2425 Rn. 33). 又Bork (Fn. 14), Rn. 545從第133條規定來看，文字只是起點，但不是解釋的標準，Bork主要應該是認為在法律行為解釋時，如果涉及當事人默示行為（konkludentes Verhalten），就沒有文字可言，無法從文字出發作為標準。類似看法Krüger-Nieland/Zöller (Fn. 31), § 133 Rn. 18特別強調文字只是構成「主要認識的來源」（Hauptkenntnisquelle）而已，只是原則上應該遵守。

¹⁴⁸ 請特別參見Hefermehl (Fn. 16), § 133 Rn. 27及該處註109所引用的學者文獻。Soergel註釋書特別以「字義不是解釋的界限」（„Wortlaut keine Grenzen der Auslegung“）作為標題，澄清此一疑問，值得注意。不過，同書另一位作者Wolf (Fn. 79), § 157 Rn. 32卻又強調「闡釋性解釋從文字出發。但以可能的字義為其界限，這個字義可能是一般的語言，也可能是專業的語言，特別是法律語言。」前後似不一致。

¹⁴⁹ Roth (Fn. 18), § 157 Rn. 3-5. „Auch ein (angeblich) klarer und eindeutiger Wortlaut einer Erklärung hindert eine ergänzende Auslegung anhand der Gesamtumstände nicht.“ 此處粗體字，為Roth所強調。並參見BGH NJW 2002, 1260 (1261).

¹⁵⁰ Bork (Fn. 14), Rn. 545; Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 5.

般商法典（ADHGB）第278條規定「法官在判斷與解釋商事行為時，應探求訂約者之意思，不得拘泥於所用之詞句」¹⁵¹，也是強調使用的文句具有重要意義。時至今日，考量文句的一般語言使用情況（Sprachgebrauch），或者有無特別地方性的、專業性的使用情況，或者甚至在當事人之間有無慣用的使用情況，也可以被認為是具有拘束力的「表達習慣」（Erklärungssitte），亦為德國民法第157條交易習慣之一部分¹⁵²。

不過無論如何，在絕大部分案件中，一般的用語還是最為重要。在德國聯邦最高法院向來被譽為、且迄今仍被視為有關契約解釋的主導性判決（als Leitentscheidung zur Vertragsauslegung）¹⁵³，即前述之「玻璃磚牆案（Glasbaustein-Urteil）」¹⁵⁴中，最高法院即援用了數本不同的辭典¹⁵⁵，將「玻璃磚牆」解為是當事人在相鄰關係之契約約定的「窗戶」。

2. 整體脈絡（文法與體系解釋 grammatische und systematische Auslegung）

文字常有多種解釋的可能，此時就應該回到文法解釋及體系解釋來作補充。前者是觀察該文字在文本中的語法脈絡，後者是觀察該用語在整體文件中的體系（脈絡）位置¹⁵⁶。這特別是在解釋大部

¹⁵¹ 參見前文對德國民法第133條的法律史觀察說明及前揭註28在本文對該條立法理由的詳細引述。

¹⁵² Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 50.

¹⁵³ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 50.

¹⁵⁴ 並參見註104以下之本文對此判決介紹。

¹⁵⁵ 並參見註107該案判決理由所列舉出，用以印證一般用語之德文相關辭典的文字解釋。

¹⁵⁶ 這是德國通說及實務的見解，只要參見BGHZ 101, 271 (273); Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 47 及該處所引用的學說及其他實務見解出處。但學者Flume (Fn. 16), S. 309雖然也列出此種文法與邏輯解釋在法律行為解釋上的可能，但基本上反持懷疑態度。主要理由是認為：「因為意思表示（法律行為）並不是像法律一樣，被加入到整體組合當中成為一致性的法秩序，所以也就不像法律有適用體系解釋的可能，這是法律解釋與法律行為解釋，二者在本質上的區分。法

頭的契約內容或者定型化契約條款時，常須連結整體契約中該條款的所在位置，特別是前後所在位置，來作闡釋性解釋，因為法律行為為自身不應該前後矛盾¹⁵⁷，而且在經驗法則上，當事人通常會是正直、理性而且體系一貫地行為¹⁵⁸。

3. 歷史解釋（historische Auslegung 或稱發生史 Vor- und Entstehungsgeschichte）

德國自1900年以後在學說及實務上就已經承認：法律行為產生之前、當時或之後的伴隨狀況或行為，必須在解釋時加以考量。也就是回溯到契約的發生史。

整個法律行為先前發生的狀況，都屬於此處的法律行為的先前史（Vorgeschichte），通常用「歷史解釋」¹⁵⁹這個上位概念涵蓋之，包括當事人在此之前所有的關係，例如以前的契約、當事人間長時間以來反覆形成的習慣、訂約當時的所有狀況、訂約之動機、訂約商議之過程、可能有訂立預約、訂約前之說明與討論、契約原來的草案等均屬之¹⁶⁰。

有疑問的是，契約成立後的狀況，特別是事後當事人間的解說、往來交換之書信及履約方式等，能否列入考量當事人的意思。關於此點，學說尚有爭論，有認為已經成立的權利義務不應該再受到一方當事人的恣意影響，但通說認為無論如何這屬於當事人訂約後的其他行為，應該可以作為間接表徵加以考量¹⁶¹。

律行為的約定內容，並沒有被要求要去實現某種法律思想，相反地，每個人都是因為個人利益而訂立法律行為，這在解釋法律行為時應該有所看見」。此項見解某程度說出了契約與法律在解釋上的不同，值得參考。

¹⁵⁷ Wolf/Neuner (Fn. 49), § 35 Rn. 7; Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 58.

¹⁵⁸ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 47, 55.

¹⁵⁹ Köhler (Fn. 95), § 9 Rn. 11; BGHZ 86, 41 (47).

¹⁶⁰ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 52.

¹⁶¹ Flume (Fn. 16), S. 300; Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 53. 並參見前揭註49所引CISG第8條第3項；PECL第5:102(b)條。

4. 目的論解釋（利益衡量與契約目的）

對法律行為的解釋而言，最重要的是當事人的利益狀態及契約規定之目的。在目的論解釋標準上，「通常經驗顯示，契約當事人會在一個無矛盾的文字下，做成符合雙方利益的，並達成其目的之理性規定」¹⁶²。應提醒的是，在此種利益狀態之目的達成下，法律行為是有可能做成違反明確文義之解釋的¹⁶³。

此外，解釋者應該盡量作成「從各方面來看均符合雙方利益的判斷」(eine nach allen Seiten interessengerechte Beurteilung)，而且不可以忽略主要利益而作解釋¹⁶⁴。例如在前述「玻璃磚牆案」中¹⁶⁵，高等法院將該相鄰關係之約定理解為安裝玻璃磚牆不在禁止之列，但該案最重要的是最高法院未直接說出的雙方利益衡量的問題。亦即：雙方契約約定之目的，被推定為在於避免來自相鄰土地的窺視與造成的影響(Einblick und Einwirkungen)，但聯邦最高法院否定這樣的解釋，因為按照高等法院的此種解釋，將會造成受到保護的鄰地所有人的土地建築權，會因為現行建築法的規定而受到重大影響，因而影響原告的主要利益¹⁶⁶。

應再特別說明者係，在目的論解釋規則之下，德國通說及實務普遍承認所謂對於免責條款有疑問時從嚴解為作不利於條款擬定人的限制解釋原則，亦即所謂「不清楚應歸主張有特別權利者負擔不利益」之一般性原則¹⁶⁷。基本法理是：經驗法則顯示，沒有人會無

162 宣示此點的德國聯邦最高法院判決無數，只要參見BGHZ 21, 319 (328); BGHZ 2, 379 (385); 30, 109 (110)即可。並參見Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 52所引文獻。

163 Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 53.

164 BGHZ 131, 136 (138); 137, 69 (72); 149, 337 (353); 150, 32 (39); 152, 153 (156).

165 Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 19, 45, 54. 並參見註103以下之本文對「玻璃磚牆案」之詳細介紹。

166 Flume (Fn. 16), S. 319.

167 參見BGHZ 5, 111 (115); 22, 90 (96); 24, 39 (45); 62, 83 (88); 67, 359 (366); 87, 246 (251); NJW 1971, 1840 (1842); Flume (Fn. 16), § 16. 3, S. 318; Singer (Fn. 12), §

故放棄現有的權利，因此，必須要有一個明確也不會造成誤解的明文約定，由該文字明白表示要放棄現有權利。反之，對於該約定負擔不利利益的制裁，就是對該約定的條款要件作嚴格取向文字的解釋（eine eng am Wortlaut orientierte Auslegung）¹⁶⁸。

5. 交易習慣

德國民法特別在第157條規定契約解釋應考量交易習慣¹⁶⁹。該規定實務上最大意義主要還是在商人的商業交易中適用的商業慣例與習慣（Handelsbräuche und Gewohnheiten）（並參見現行德國商法第346條¹⁷⁰，德國因採民商分立原則，主要適用在商人之間），但必須是一個事實上在特定商業圈已經通行的慣習（Übung）¹⁷¹，亦即，在契約解釋時應遵守之原因，並不是因為將交易習慣視為一個法律規範，而是仍將其視為意思表示解釋的事實因素（tatsächliches Moment）¹⁷²，因此主要還是要歸因於一般經驗法則，因為所有法律交易的參與者均已習慣遵守在該交易圈內所存在的習俗與慣例

133 Rn. 63. 此外，德國2002年債法修正已增訂的第305c條所謂一般交易條款法規定也將此原則廣泛明文化，該條原文為：(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil. (2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders. 參考國立臺灣大學法律學院財團法人台大法學基金會，德國民法（上）：總則編、債編、物權編，2版，頁302（2016年），譯為：「（第Ⅰ項）定型化契約按其情事，即如依契約外在之表現型態不尋常，提出者之相對人無須有所預期者，不構成契約之內容。（第Ⅱ項）定型化契約之解釋，有疑義時，提出者負擔其不利益。」又臺灣消費者保護法第11條第2項也有類似規定「定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋」可供參照。

168 Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 53.

169 有少數認為交易習慣也屬於體系解釋的一部分者，參見Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 59.

170 同註43。

171 RGZ 49, 157 (162); BGH LM Nr. 1 zu § 157(B).

172 Flume (Fn. 16), S. 312.

(Sitten und Gebräuche)¹⁷³。因此交易習慣原則上是指「在所有交易生活中參與相關領域的交易圈，所已經形成的一致的觀念」¹⁷⁴。至於一般交易行為，相對而言較少形成交易習慣¹⁷⁵。

不過，一般認為，交易習慣「本身」即應適用於意思表示的解釋，不論表意人或相對人是否知悉或者應該知悉該交易習慣¹⁷⁶。

6. 誠信原則

誠信原則作為概括條款原則上當然無法以概念推論或涵攝方式為之，毋寧如所周知地須透過下位原則具體化，如前所述地，這是受到德國民法第242條之影響而增訂第157條。但綜合言之，誠信原則是屬於客觀規範性解釋，應該考量意思表示之相對人有值得保護的信賴，應考量所有當事人的正當利益，以及對於正直商業交易的要求（Anforderungen eines redlichen Geschäftsverkehrs）¹⁷⁷。但無論如何，誠信原則就是透過引進「法律行為以外的其他價值判斷標準（außergeschäftliche Wertungsmaßstäbe）」以求得個案的衡平性¹⁷⁸。

三、解釋標準間之位階關係？

與法律解釋一樣，解釋的結果難以確保其「正確的解釋」，契約的解釋亦同¹⁷⁹。因此契約解釋的標準（或要素）的難題仍然在於：各標準間有無優先的（嚴格優位的）位階關係？例如，如果文法解釋的結果與訂約時所伴隨的狀況不一致時，何者優先？文字解釋與目的論解釋齟齬時，契約之目的論解釋是否應該優位？對此，

¹⁷³ Wolf/Neuner (Fn. 49), § 28 Rn. 62.

¹⁷⁴ BGH LM Nr. 1 zu § 157(B).

¹⁷⁵ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 64.

¹⁷⁶ Flume (Fn. 16), S. 313.

¹⁷⁷ Singer (Fn. 12), § 133 Rn. 63; Busche (Fn. 20), § 157 Rn. 6 ff.

¹⁷⁸ Vogenauer (Fn. 7), §§ 133, 157 Rn. 67 ff.

¹⁷⁹ Flume (Fn. 16), S. 314.

迄今並未被提出特定順序優位的定論，故一般強調仍應綜合評價整體狀況，因為這些標準或因素都只是被作為單純的表徵，用以推測表意人法律上的重要意思而已；只不過評價時並非任諸適用法律者自由喜好，而應遵守法定的或普遍承認的解釋規則、邏輯思維與經驗法則等，綜合考量。

雖然有學說認為目的論應該某程度具有解釋上的優位¹⁸⁰，但通說仍然認為此種他律性的評價（heteronome Wertungen）仍然不得超越明白可知的、與目的論評價相反之當事人經驗的意思。故私法自治原則仍應該優先¹⁸¹。

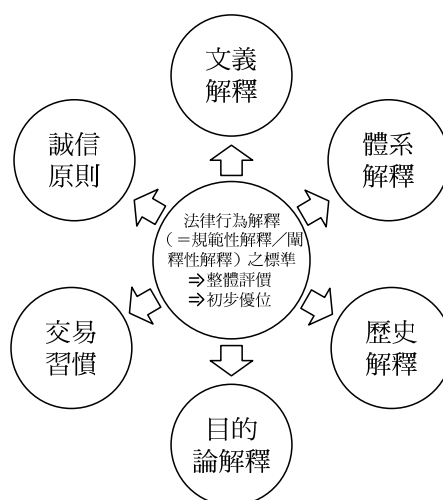


圖5 法律行為解釋之標準

資料來源：作者自製。

180 此在法律解釋方法上，頗被喜好，雖然尚未成為通說，但例如BGHZ 17, 267 (276); *Singer* (Fn. 12), § 133 Rn. 70均有此傾向。國內最近學說參考德國近年發展趨勢，認為對於法律解釋有採取所謂目的論解釋，雖不具有「嚴格優位」，但應該賦予「初步優位」（可嗣後舉反證推翻）之見解者，此點在契約解釋上可供參考，參見吳從周（註133），頁491-524。

181 *Singer* (Fn. 12), § 133 Rn. 48, 70.

四、觀察臺灣法院的契約解釋類型

(一)「六準則」之宣示

如前所述地，最高法院除了在本文一開始的「巴里島社區案」外，最近更直接在前述「直升機維修案」(最高法院103年度台上字第713號民事判決)中，第一次明白使用「闡明性解釋」與「補充性解釋」概念，並且強調「進行此項闡明性之解釋(單純性之解釋)，除依文義解釋(以契約文義為基準)、體系解釋(綜觀契約全文)、歷史解釋(斟酌訂約時之事實及資料)、目的解釋(考量契約之目的及經濟價值)並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷」，明白採取「六準則」。

(二)「六準則」之貫徹？

問題在於，除了上開判決曇花一現式地宣示外，在其前後之最高法院判決，似對於法律行為或契約之解釋標準，任意記載，龐雜不已。僅以最高法院的判決加以觀察，有關契約解釋之判決甚多¹⁸²，下文僅先大致歸納幾種法院判決的解釋標準論述類型，以觀察臺灣法院之契約解釋，究係採取如何之考量標準，其中特別挑選以最新的臺灣最高法院2013年至2017年所作成的判決為例進行討論，再輔以「六準則」作歸納。無獨有偶地，僅僅以2013年(最高法院102年度字號)之判決，就恰巧可以歸納出主要的四種類型。據此，期待能藉由類型化觀察，貫徹「六準則」說，達到具體化思

¹⁸² 如果分別以「法律行為解釋」或「契約解釋」或「民法第九十八條」為關鍵字，鍵入司法院法學資料檢索系統加以查詢，僅相關最高法院之判決總計即已累積多達298筆以上(最後瀏覽日：2017年9月4日)。由於本文此處係以整理與檢討法院判決中對於法律行為解釋或契約解釋使用之「標準」或「要素」為何，並檢討其與本文建議的「六準則說」之關係，故在此等眾多法院判決的選取上，除了本文特別提到之「巴里島社區案」或「直升機維修案」等具有代表性判決外，主要以近五年即2013年至2017年所作成之判決為主，附此敘明。

維之效果，使臺灣判決上涉及法律行為或契約之解釋標準者，能有較高的明確性標準，供訴訟當事人參考，提高法律行為解釋結果之可預測性。

1. 類型化觀察：四大論述類型

【類型一：契約文字已表達當事人真意】

最高法院102年度台上字第297號民事判決謂：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字更為曲解，此觀保險法第五十四條第二項及民法第九十八條規定自明。¹⁸³」

另一種類似講法為最高法院103年度台上字第562號民事判決：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八條定有明文。故解釋當事人之契約，應於文義上及論理上詳為推求，不得拘泥字面，致失當時立約之真意。」

此種標準顯然承繼前述該院17年上字第1118號民事判例（文義說）之見解而來：「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨文字而更為曲解。」

【類型二：依當時事實與其他一切證據】

最高法院102年度台上字第32號民事判決：「按解釋契約應以當事人立約時之真意為準，而真意何在？又應以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準。¹⁸⁴」

相同意旨但類似敘述，亦有最高法院102年度台上字第1392號民事判決（分割產權登記案）強調：「按解釋契約，應以當事人立約當

¹⁸³ 並參見最高法院102年度台上字第905號、1292號、2356號、2477號等民事判決、最高法院103年度台上字第561號民事判決。

¹⁸⁴ 另可參見最高法院102年度台上字第349號民事判決。

時之真意為準。而真意何在，除通觀全文，於文義上及論理上詳為推求外，並應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準。¹⁸⁵」

不過，此判決有略加分析之必要。

【案例事實】

本件事實可以簡化如下：

甲（原告＝上訴人）起訴請求乙（被告＝被上訴人）應將系爭土地所有權應有部分1/3移轉登記於甲。蓋乙之被繼承人江木根曾向甲買賣系爭土地（共有ABCDEFG七區）中的ABCDG區，已移轉於乙，因系爭土地為田地，受當時法令限制，無法分割移轉，乃將系爭土地移轉登記與江木根，並約定其保留未出售之EF部分暫借名登記在江木根名下，俟日後得分割移轉時，江木根即分割移轉返還之。江木根已於94年2月2日死亡，其與甲間之借名契約關係即歸消滅，乙為江木根之繼承人，乃訴請甲請求乙返還借名登記權利。

【本件爭點】

本件買賣契約約定：「因受現行法令限制，不能申請分割，全筆土地登記所有權人為乙方（即江木根），日後法令允許分割登記時，乙方無條件與甲方（即上訴人）分割登記之」，據此，究竟甲方僅得請求乙方辦理「分割登記」抑或得請求辦理所有權應有部分移轉（＝移轉為共有登記）之「產權登記」？

【高等法院見解】

二審臺灣高等法院臺中分院從文義解釋的角度認為僅限於請求辦理「分割登記」，因此原告起訴請求辦理「所有權應有部分移轉登記」不應准許。其理由為：買賣契約明文約定「因受現行法令限制，不能申請分割，全筆土地登記所有權人為乙方（即江木根），日後法令允許分割登記時，乙方無條件與甲方分割登記之」，可見

¹⁸⁵ 最高法院102年度台上字第1387號民事判決同旨。

上訴人因締約當時農業發展條例第30條「每宗耕地不得分割及移轉為共有」規定之限制，而將系爭土地其未出售部分借名登記於江木根名下。而江木根已於2005年2月2日死亡，其與上訴人間之借名契約關係即歸消滅，被上訴人為江木根之繼承人，上訴人請求被上訴人返還借名登記權利，即非無據。揆買賣契約上開約定，乃就江木根應分割登記上訴人保留所有權部分之債務，附有「法令修改允許分割」之停止條件；參以修正前農業發展條例第30條規定係並列耕地不得「分割」及「移轉為共有」二項限制，上開約定僅記述「分割」，未提及「移轉為共有」，暨上訴人與江木根各自管理使用保留、買受區域，足見其雙方期就系爭土地擁有各自獨立產權，無移轉共有之意。是上訴人僅得於法令允許分割時，請求被上訴人分割移轉系爭土地其所保留借名登記之E、F區合計共655.77平方公尺之特定土地，而不得請求將該特定土地換算為應有部分，請求移轉為共有。

【最高法院見解】

但最高法院以下列理由廢棄高等法院之判決：按解釋契約，應以當事人立約當時之真意為準。而真意何在，除通觀全文，於文義上及論理上詳為推求外，並應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，以不失當事人之立約真意。查上訴人與江木根買賣系爭土地之一部，受買賣當時法令之限制，無法分割移轉，乃將系爭土地全部移轉登記與江木根所有，約定俟日後得分割移轉時，江木根即應分割移轉返還等情，為原判決認定之事實。果爾，以締約當時農業發展條例第30條「每宗耕地不得分割及移轉為共有」之限制規定觀之，上訴人與江木根買賣當時，乃無法以「分割」或「移轉為共有」任一方式為買賣土地所有權移轉登記之履行；倘當時依上訴人出售面積與整筆面積比例計算應有部分移轉與江木根之「移轉為共有」方式為可行，上訴人與江木根是否會堅持「土地分割」方式，而捨該途，合意整筆土地移轉登記為江木根所有？若否，買賣

契約所為「因受現行法令限制，不能申請分割，全筆土地登記所有權人為甲方，日後法令允許『分割登記』時，甲方無條件與乙方分割登記之」約定，該「分割登記」解釋上是否僅限於土地位置與面積之「土地分割」登記，而不包括所有權應有部分移轉之「產權分割」登記？並非無疑。自有詳為推求之必要。乃原審未察土地共有人非不得約定各自管理收益特定部分土地之情，徒憑上訴人及江木根各自管理收益系爭土地之一部，即論斷買賣契約約定之「分割登記」及於「產權分割」之移轉為共有登記，已不免失之速斷。

【分析說明】

本件高等法院顯然以契約文義僅明確記載「『分割』，未提及『移轉為共有』」，已表明其真意，自無另外擴張解為包括「移轉應有部分」之可能。

但最高法院以「締約當時」之農業發展條例第30條「每宗耕地不得分割及移轉為共有」之規定，推論兩造間本有「移轉為共有」或「土地分割」兩種買賣土地所有權移轉登記之方式，而將系爭買賣契約約定之「分割登記」解為包括所有權應有部分移轉之「產權分割」登記（亦即以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準）而探求當事人真意，似已過度推論擬制當事人之真意而超過契約之文義範圍，蓋將所有權應有部分移轉為共有之登記刻意稱為「產權分割」登記，似尚未之見而為本判決所獨創，只為配合契約辭句使用之「產權分割」登記而已，尚難令人信服。

但究其實，其實最高法院的真正論據應該在於「原審未察土地共有人非不得約定各自管理收益特定部分土地之情」這句話，也就是最高法院其實考量到透過所有權移轉為共有之登記，比拘泥於「分割登記」，更能達到土地所有權人（將其名下之）物盡其用之經濟目的，符合當事人之利益衡量。只不過，將此種論證對應於論證大前提的「過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準」，力道似

嫌不足，其論證依據反而較接近下述之「本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察」之結果。

【類型三：通觀全文、契約目的與經濟價值】

第三類論述理由為最高法院102年度台上字第748號民事判決：「按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎。」

【案例事實】

甲（買受人＝原告＝本件被上訴人）起訴主張伊向乙（出賣人＝被告＝本件上訴人）購買系爭房地，於2005年6月22日簽訂不動產買賣契約，並於2005年12月2日將價金（含現金新台幣850萬元及承擔上訴人銀行貸款1,050萬元）全數付清，乙已出具合約收據，並於當日交屋，且約定交屋一年後即2006年12月2日辦理過戶，乙迄仍拒不過戶。甲乃依契約訴請乙辦理房地移轉登記。乙則抗辯：甲並未依約以系爭房地，另向系爭房地之貸款銀行（安泰銀行）辦理貸款，以變更原貸款銀行之債務人為甲而清償貸款餘額，故乙得行使同時履行抗辯權，拒絕辦理房地所有權移轉。

【本件爭點】

本件爭議之關鍵在於：兩造之契約究竟有無約定，甲應變更貸款銀行之債務人，而以甲之名義繳納貸款？此涉及本件兩造契約如何解釋。

【高等法院判決理由】

臺灣高等法院維持地方法院之見解，對契約解釋之結果均採否定說。主要針對本件契約三個條款解釋，理由如下：

1. 依系爭契約第14條特約事項記載：「本件買賣交屋日前未償還銀行貸款利息由乙方（上訴人）負擔，交屋日後之房貸利息由甲方（被上訴人）承接繳納」，可知被上訴人自交屋日即2005年12月2日起即應負擔安泰銀行之貸款利息。上訴人固辯以被上訴人未依約以自己提供之擔保品向銀行申辦貸款以付清價金云云；被上訴人對之已稱兩造約定由其承擔1,050萬元之安泰銀行貸款，仍以上訴人之名義繳納而未變更債務人等語。

2. 依系爭契約第2條關於付款期限及移交不動產方法：「（二）第貳次付款：甲方（被上訴人）辦妥產權登記及銀行貸款後，償還乙方（上訴人）原貸款額，雙方結算付清尾款」所載，核其文義，亦未約定由被上訴人取代上訴人另行提供擔保品申貸。

3. 合約收據記載「銀行一千零五十萬元利息，交屋後由蔡鴻祺（被上訴人配偶）付款」，亦未提及須變更安泰銀行貸款債務人。果若兩造確實約定應變更債務人名義，則於被上訴人未履行前，上訴人豈可能於合約收據上載明尾款加上銀行貸款全數收訖？

4. 參諸被上訴人於交屋後按月陸續繳納安泰銀行貸款利息多年，如其依約應以自己提供之擔保品向銀行申辦貸款以付清尾款，上訴人怎會延宕多年均未請求被上訴人為之？自難認上訴人上開抗辯屬實。上訴人既未能證明被上訴人有何違約情事，其依系爭契約第10條為解除契約之意思表示，自非有據。

【最高法院判決理由】

但最高法院則以如下判決理由廢棄高等法院判決：

按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。查系爭

契約分於第2條第2款約定「(二)第貳次付款：甲方(被上訴人)辦妥產權登記及銀行貸款後，償還乙方(上訴人)原貸款額，雙方結算付清尾款」，第8條約定「……甲方應於貸款手續中無條件提供必備之證件及足夠擔保貸款額度之擔保物，若係甲方信用條件不合或金融政策改變，以致貸款額度不足時，甲方應於撥款時以現金一次補足，貸款應於產權移轉手續完成三周內付清，甲乙雙方並約定於『尾款付清日』將房屋騰空交與甲方……」，綜觀系爭契約上開前後有關「貸款」之約定，似謂被上訴人應另行申辦銀行貸款，以償還上訴人原有之安泰銀行貸款。果爾，則被上訴人主張兩造約定其承擔原銀行貸款1,050萬元，當不變更貸款債務人，仍以上訴人名義繳納一節，是否即表示被上訴人已依系爭契約「辦妥銀行貸款，以償還上訴人原貸款項」？能否以之逕認上訴人所辯被上訴人未依約以自己擔保品向銀行貸款，以付清價金云云為不足取？即非無疑。究竟兩造系爭契約之真意為何？被上訴人所稱銀行貸款仍以上訴人名義繳納之主張，與上訴人所為被上訴人未申辦貸款付清價金之抗辯有何關連？上訴人此項同時履行之抗辯，是否有理由？自有待釐清。原審未遑進一步調查審認兩造間約定之真意，徒以第2條第2款文義即謂兩造未約定由被上訴人另行申貸以償還原貸款，進而為上訴人同時履行抗辯不利之論斷，不免速斷。又系爭契約除有約定貸款事項外，並於第14條特約事項記載：交屋日前未償還之銀行貸款利息由上訴人負擔，交屋日後之房貸利息由被上訴人承接繳納等語，此似僅涉及兩造間分擔貸款利息之約定，上訴人就此曾抗辯：伊於合約收據記載「銀行一千零五十萬元利息，交屋後由蔡鴻祺付款」，祇是確定系爭契約第14條之真意，並非免除被上訴人另行申辦貸款以償還伊原有貸款等語，是否全然無據？亦非無再事推求之必要¹⁸⁶。

186 相同判決論證理由，見最高法院102年度台上字第1896號民事判決涉及對於遺囑之解釋。

【分析說明】

1. 最高法院在論述理由的大前提中臚列的諸多契約解釋的要素，包括：「通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察」，但其實真正在小前提中所用到的要素，只有「通觀契約全文」（例如判決理由謂「綜觀系爭契約上開前後有關「貸款」之約定」），其他要素似均未見討論，涵攝過程因此顯得較為空洞化，較可惜地浪費了大前提中對於重要契約解釋因素之意識。

2. 其他理由則在指正高院對於條款的文義解釋有誤，不應該作如此之解釋（例如判決理由謂「第14條特約事項記載……僅涉及兩造間分擔貸款利息之約定，……合約收據記載『銀行一千零五十萬元利息，交屋後由蔡鴻祺付款』，祇是確定系爭契約第14條之真意，並非免除被上訴人另行申辦貸款以償還伊原有貸款」），並未涉及交易習慣、經驗法則、誠信原則、契約目的、經濟價值等全盤觀察之結果。

3. 相反地，原審高等法院之理由（上文所列之4.）中有關「如其依約應以自己提供之擔保品向銀行申辦貸款以付清尾款，上訴人恁會延宕多年均未請求被上訴人為之」等涉及「經驗法則」之論證，反而未見最高法院反駁指摘。

【類型四：原因事實、經濟目的、解釋結果與公平原則】

除了上開三種類型敘述之解釋標準外，另一種近年來愈來愈受喜愛使用者，係以下之解釋標準論證方式，從使用此類型論述的判決數量上來看，似乎可以認為是法院實務的通說。這類型大概又有以下幾種論述的亞型。

最高法院102年度台上字第2087號民事判決謂：「按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八

條定有明文。所謂探求當事人之真意，乃在兩造就其意思表示真意有爭執時，應從該意思表示所植基之原因事實、經濟目的、社會通念、交易習慣、一般客觀情事及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果是否符合公平原則。¹⁸⁷」

最高法院102年度台上字第2211號民事判決謂：「按解釋契約應探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，作全盤之觀察，不得拘泥字面或截取書據中一、二語，任意推解。¹⁸⁸」

又最高法院102年度台上字第2272號民事判決謂：「按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，資以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平。」

2. 解釋標準之歸納重整

以上開引用約五年左右引用的臺灣最高法院判決中所使用過的解釋標準，筆者初步歸納起來就多達19個，呈現日漸龐雜繁複的解釋標準，容易使法律行為解釋之論證標準失焦。茲列表並從「六準則說」的角度分析說明如下：

187 相同判決論證文字，見最高法院103年度台上字第431號、1537號、1667號、2067號、2251號、2655號等民事判決、104年度台上字第1575號（「……藉以檢視其解釋結果是否符合公平正義」）、2305號、2369號等民事判決、105年度台上字第211號、595號、842號、1710號、2240號等民事判決、106年度台抗字第445號民事裁定。

188 相同論述理由，最高法院106年度台上字第254號民事判決。

表1 實務解釋標準之綜合對照

編號	解釋標準 (要素)	判決字號 (以下判決中均使用此等 要素)	分析說明
1	契約文字(所用 辭句)、文義	最高法院102年度台上字 第297民事判決	文義解釋
2	當時事實、過 去事實	最高法院102年度台上字 第32民事判決	法律行為成立之前、當時的伴 隨狀況或行為，屬歷史解釋
3	其他一切證據 資料	最高法院102年度台上字 第32民事判決	法律行為成立之前、當時的一 切伴隨狀況或行為，屬歷史解 釋
4	通觀全文、通 觀契約全文	最高法院102年度台上字 第1392民事判決	是觀察該用語在整體文件中的 體系(脈絡)位置，屬體系解 釋
5	論理	最高法院102年度台上字 第1392民事判決	「論理」本為邏輯之意，故此 乃指觀察該文字在文本中的語 法脈絡而言，屬體系解釋
6	交易(上之)習 慣	最高法院102年度台上字 第748民事判決 最高法院102年度台上字 第2087民事判決 最高法院88年度台上字 第1671民事判決	重申「交易習慣」
7	經驗法則	最高法院102年度台上字 第748民事判決	應係指「所有法律交易的參與 者均已習慣遵守在該交易圈內 所存在的習俗與慣例」之一般 經驗法則，屬交易習慣之內涵
8	誠信原則	最高法院102年度台上字 第748民事判決 最高法院88年度台上字 第1671民事判決	重申「誠信原則」
9	契約(之主要) 目的	最高法院102年度台上字 第748民事判決	重申法律行為之目的，屬目的 論解釋

	意思表示之目的性	最高法院88年度台上字第1671民事判決	
10	經濟價值	最高法院102年度台上字第748民事判決	似屬強調法院應做成符合雙方利益衡量的價值判斷，屬目的論解釋
11	意思表示植基之原因事實	最高法院102年度台上字第2087民事判決	應係指法律行為成立當時或訂約當時，一切伴隨狀況，屬歷史解釋
12	經濟目的	最高法院102年度台上字第2087民事判決	此之「經濟目的」究指契約目的或經濟價值？如是後者，則似屬強調法院應做成符合雙方利益衡量的價值判斷，不過二者在學說上均被認為是目的論解釋
13	社會通念	最高法院102年度台上字第2087民事判決	此所謂「社會通念」是針對何種內容而言，不甚清楚。如係指「交易生活中參與相關領域的交易圈，所已經形成的一致的觀念，則屬於交易習慣之內容。但因過於含糊，建議將來判決中應不要再使用
14	社會客觀認知	最高法院102年度台上字第2211民事判決 Q：與社會通念或一般客觀事實有何不同？	與前述「社會通念」有無不同？如係指「交易生活中參與相關領域的交易圈，所已經形成的一致的觀念，則屬於交易習慣之內容。但因過於含糊，建議將來判決中應不要再使用
15	一般客觀事實	最高法院102年度台上字第2087民事判決 Q：與當時事實、過去事實、意思表示植基之原因事實，有何不同？	此與前述之當時事實、過去事實、意思表示植基之原因事實，有何不同？如是，則屬法律行為成立之前、當時的一切伴隨狀況或行為，屬歷史解釋。但因內容過於含糊，建議將來判決中應不要再使用

16	當事人意欲之法律效果？	最高法院102年度台上字第2087民事判決	當事人意欲之法律效果，正是契約解釋應加以探求者，且如前述地，因為已先透過「經驗性解釋」無法得出契約雙方當事人「一致理解的意思表示之意義與效果」，故有進一步運用此處之「闡釋性解釋」而探求客觀規範上當事人「可能的意思」之必要，故在判決中重申「當事人意欲之法律效果」，不僅可能混淆「經驗性解釋」與「闡釋性解釋」，且對於法律行為解釋標準與結果，並無助益
17	解釋結果是否符合公平原則或公平正義、解釋結果對兩造權義是否符合公平	最高法院102年度台上字第2087民事判決 最高法院102年度台上字第2272民事判決 最高法院104年度台上字第1575號民事判決	透過誠信原則的引進與調整，正是為求「個案的衡平性」(公平性)，故此處之意涵應係指以誠信原則調整解釋結果而言
18	法律行為之和諧性	最高法院88年度台上字第1671民事判決	應是強調解釋應注意使法律行為規定，在體系上前後無矛盾，屬體系解釋
19	任意法規	最高法院88年度台上字第1671民事判決	任意法規應屬於補充性解釋適用之層次，與闡釋性解釋無關

資料來源：作者自製。

上開要素尚不乏用語相近，但內涵並不清楚，所指涉者是否相同標準，未見最高法院統一使用之情形者。

而且，這當中更不乏誠信原則、公平原則、法律行為之和諧性等諸多空洞的不確定法律概念，作為契約解釋時法院適用法律之大前提。在實際適用上恐難期待下級法院引用時，能夠明確認定待涵攝之具體事實（小前提）究竟屬於何者，而得以精確涵攝。此由上

開【類型三】之涵攝過程，最高法院列舉了「解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察」等標準，作為大前提，但在實際的小前提認定上，其實只有「文義」以及「綜觀系爭契約上開前後有關……之約定」（＝通觀契約全文），其他大前提根本均未使用，喪失列舉諸多大前提之意義。相較而言，本文一開始的最高法院88年度台上字第1671號民事判決中同時運用契約文義、當事人契約目的、誠信原則以及定型化契約有利於弱勢消費者之解釋（參見消保法第11條第2項），並以後三者推翻契約文義解釋，估不論結論是否可資贊同，至少論證上較為詳盡。

茲嘗試基於上開對於最高法院使用之標準的說明，以「六準則說」重新整理解釋之標準，圖示如下供參考：

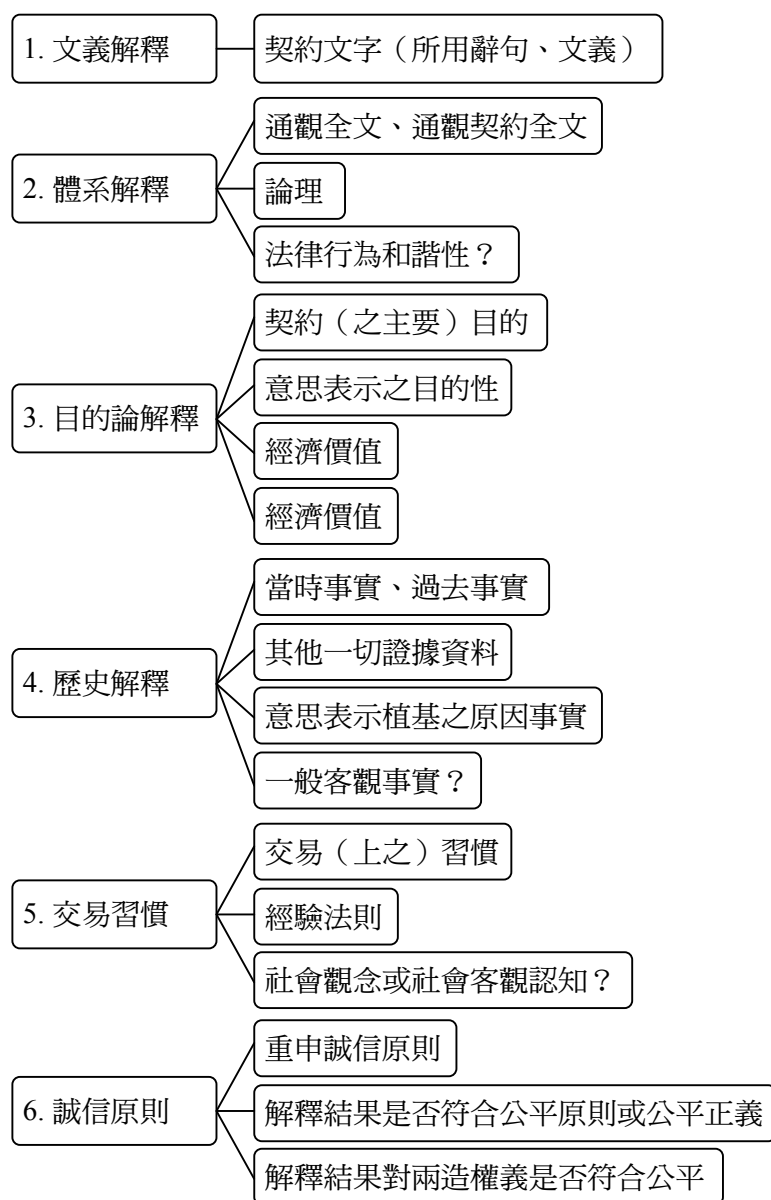


圖6 以六準則重整實務解釋之標準

資料來源：作者自製。

肆、結論

本文從德國法繼受的立法溯源及反思臺灣法在實務上之運用，研究我民法第98條涉及的兩個核心問題：法律行為解釋與契約解釋有何不同？法律行為解釋與法律解釋在解釋標準上如何運用？綜合上開論述，本文主要提出兩點結論供參考。

第一、德國法關於法律行為解釋與契約解釋，分別有德國民法第133條及第157條交錯規定，這兩條解釋規則內容雖然相互補充，但卻均為不完整的指示規定，本身即有待進一步具體化。臺灣民法雖然沒有第157條規定，但卻透過實務見解的運作，自行解決了經驗性解釋與規範性解釋（闡釋性解釋）的「真意」探求問題，迴避了德國法上開繁雜冗長的爭論過程。此外，我國在對於第98條「探求當事人真意」之理解上，應該避開意思說與表示說之爭論，不必再去思考探求「當事人主觀真意」之誤解，而是應由法官透過法律行為解釋的三階段：經驗性解釋、規範性解釋（闡釋性解釋）與補充性解釋之方法，確定當事人「真正被表示的意思」。

第二、在最主要的闡釋性解釋上，涉及法律行為解釋與法律解釋在解釋標準上之運用，我最高法院曾經明白宣示過「六準則說」，但在本文一開始「巴里島社區案」判決，關於法律行為之解釋方法使用了包括契約目的、習慣、任意法規及誠信原則等標準及其優位順序，卻與其餘法院判決以及德國通說實務見解不同。本文透過對臺灣法律判決實務中對法律行為解釋標準之歸納與重整，歸納出主要的四種類型，但卻累計多達數十種空泛的解釋標準，期待能藉由類型化之觀察重整，貫徹「六準則說」，以提高臺灣判決實務涉及法律行為或契約之解釋標準與解釋結果之預測性。

參考文獻

1. 中文部分

- Franz Wieacker著，陳愛娥、黃建輝譯（2004），近代私法史，臺北：五南。[Wieacker, Farnz (1996), *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen: Vandenhoeck & Puprecht.]
- 王文字（2009），契約定性、漏洞填補與任意規定：以一則工程契約終止的判決為例，臺大法學論叢，38卷2期，頁131-186。
- 王澤鑑（2014），民法總則，增訂新版，臺北：王慕華。
- 史尚寬（1990），民法總論，臺北：自版。
- 朱慶育（2004），意思表示解釋理論，北京：中國政法大學出版社。
- （2016），民法總論，2版，北京：北京大學出版社。
- 李其陸（2015），法律行為解釋之理論與實務——以契約之解釋為中心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 吳從周（2017），台灣民法方法論之發展現況——特別聚焦法律解釋方法在法院實務之運用狀況，收於：戴東雄教授八秩華誕祝壽論文集委員會編，身分法之回顧與前瞻——戴東雄教授八秩華誕祝壽論文集，頁491-524，臺北：元照。
- 施啟揚（2007），民法總則，臺北：自版。
- 洪遜欣（1987），中國民法總則，修訂再版，臺北：自版。
- 國立臺灣大學法律學院財團法人台大法學基金會（2016），德國民法（上）：總則編、債編、物權編，2版，臺北：元照。
- 黃茂榮（2009），法學方法與現代民法，增訂6版，臺北：自版。
- 鄭玉波、黃宗樂（2004），民法總則，修訂9版，臺北：三民。
- 龍衛球（2000），民法總論，北京：中國法制出版社。

2. 外文部分

- Ahrens, Martin (2017), in: Prütting/Wegen/Weinreich (Hrsg.), BGB Kommentar, 12. Aufl., Köln: Luchterhand, § 133.
- Arnold, Arnd (2014), in: Westermann (Hrsg.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. I, 14. Aufl., Köln: Dr. Otto Schmidt, § 133.
- Bickel, Dietrich (1976), Die Methoden der Auslegung Rechtsgeschäftlicher Erklärungen, Marburg: Elwert.
- Bork, Reinhard (2016), Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 4. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- Busche, Jan (2012), in: Säcker (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl., München: C. H. Beck, § 133.
- Cordes, Albrecht (1991), Der Haakjöringsköd-Fall (RGZ 99, 147-149), Jura, S. 352-357.
- Danz, Erich (1897), Die Auslegung der Rechtsgeschäfte: Zugleich ein Beitrag zur Rechts-und Thatfrage, Jena: Fischer.
- Flume, Werner (1979), Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II: Das Rechtsgeschäft, 3. erg. Aufl., Berlin: Springer-Verlag.
- Heck, Philipp (1914), Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, AcP 112, S. 1-318.
- Hefermehl, Wolfgang (1999), in: Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. II, 13. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer, § 133.
- Kilian, Wolfgang (1976), Zur Auslegung zivilrechtlicher Verträge, in: Koch (Hrsg.), Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, Kronberg: Athenäum, S. 271-286.
- Köhler, Helmut (2015), BGB Allgemeiner Teil, 39. Aufl., München: C. H. Beck.
- Kramer, Ernst A. (1972), Grundfragen der vertraglichen Einigung:

Konsens, Dissens und Erklärungsirrtum als dogmatische Probleme des österreichischen, schweizerischen und deutschen Vertragsrechts, München: Fink.

Krüger-Nieland, Gerda/Zöller, Richard (1982), in: Mitglieder des Bundesgerichtshofes (Hrsg.), Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes (RGRK-BGB), Bd. I, 12. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter, § 133.

Larenz, Karl (1930), Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts: Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Willenserklärung, Frankfurt a.M.: Werner Scholl.

Lüderitz, Alexander (2000), in: Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. XIII: Schuldrechtliche Nebengesetze 2. CISG, 13. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer, Art. 8.

Medicus, Dieter (2010), Allgemeiner Teil des BGB, 10. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

Mugdan, Benno (1899), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Bd. I, Berlin: R. v. Decker.

Raiser, Ludwig (1935), Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.

Roth, Herbert (2016), in: von Staudinger (Hrsg.), Staudinger BGB, Berlin: Sellier-de Gruyter, §§ 139-163.

Scherer, Inge (1988), Die Auslegung von Willenserklärungen „klaren und eindeutigen“ Wortlauts, Jura, S. 302-305.

Singer, Reinhard (2004), in: von Staudinger (Hrsg.), Staudinger BGB, Berlin: Walter de Gruyter, §§ 90-133.

Titze, Heinrich (1936), Rechtsgeschäft, in: Schlegelberger (Hrsg.), Rechtsvergleichendes Handwörterbuch, Bd. V, Berlin: F. Vahlen, S. 789-845.

Vogenauer, Stefan (2001), *Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent: Eine vergleichende Untersuchung der Rechtsprechung und ihrer historischen Grundlagen*, Bd. I, Tübingen: Mohr Siebeck.

——— (2003), in: Schmoeckel (Hrsg.), *Historisch-kritischer Kommentar zum BGB*, Bd. I, Tübingen: Mohr Siebeck, §§ 133, 157.

Wendtland, Holger (2012), in: Bamberger/Roth (Hrsg.), *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 3. Aufl., München: C. H. Beck, § 157.

Wieacker, Franz (1967), *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, JZ, S. 385-391.

Wieser, Eberhard (1985), *Empirische und normative Auslegung*, JZ, S. 407-410.

——— (1989), *Wille und Verständnis bei der Willenserklärung*, AcP 189, S. 112-121.

Windscheid, Bernhard (1867), *Lehrbuch des Pandektenrechts*, Bd. I, 2. Aufl., Düsseldorf: Buddeus.

——— (1880), *Wille und Willenserklärung: Eine Studie*, AcP 63, S. 72-112.

Wolf, Manfred (1999), in: Soergel (Hrsg.), *BGB*, Bd. II, 13. Aufl., Stuttgart: Kollhammer, § 157.

Wolf, Manfred/Neuner, Jörg (2016), *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 11. Aufl., München: C. H. Beck.

The Interpretation of Judicial Act, of Contract and of Law:

Focusing on Legislative Tracing of Taiwan Civil Code
Article 98 and Its Practical Use

*Chung-Jau Wu**

Abstract

This article traces the source of Taiwan's legislation, which was mainly inherited from German law, in order to reflect on the practical application of Taiwan law. The study of Article 98 of Taiwan Civil Code involves two core issues: What is the difference between the interpretation of judicial acts and that of contract? How does the interpretation of judicial acts and legal interpretation work in interpreting standards?

First, in understanding Taiwan Civil Code Article 98, we should avoid misunderstanding the so-called "seeking the Truth of the Parties" which misleads us to seek the "subjective truth" of the parties. This article should be explained by the judge during the main stage of interpretation of juridical acts, that is, normative interpretation (interpretive interpretation) to determine the parties' "true expressed meaning".

Second, the Supreme Court has clearly declared "six criteria" in the most important stage of explanatory interpretation involving the standard of interpretation of juridical acts and the use of legal interpretation. This paper summarizes the four major types of interpretation of juridical acts

* Associate Professor, College of Law, National Taiwan University.

from hundreds of Taiwan's legal judgments and re-categorizes them, with an eye to improving the transparency and the predictability of Taiwan's judicial interpretation of contracts.

KEYWORDS: interpretation of judicial act, interpretation of contract, interpretation of law, empirical explanation, interpretive explanation, supplementary explanation, true meaning, expression, theory of meaning, theory of expression.